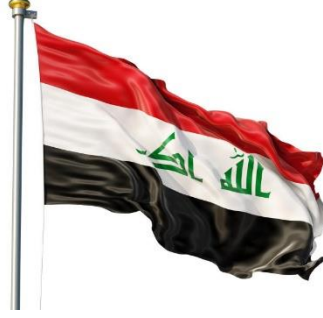




الامنياز في ايجاز القضاء الاداري

إعداد | محمود السيد

البنفسج يجمعنا. ♥



كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك

"كيفما تكونوا يوكى عليكم"



تم نشر الملف في قناة شبكة قانونيون على التكرام
تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الكتب
القانونية الدراسية والعامة بالإضافة الى الملازم ،
الملخصات ، نماذج دعاوى مختلفة ، المتون
القانونية ، وغيرها من الأمور .

رابط القناة اذا كنت ترغب في الانضمام معنا ↓

https://t.me/iraq_law5

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

"لا يحصل برد العيش إلا بحرّ النصب ، ومن اتبع الأهواء ، ركب الأهوال"

وبعد

أحبتني طلبة المرحلة الثالثة لقسم القانون في عموم العراق تُهديكم ونضع بين أيديكم هذا الإيجاز في تقليص وتلخيص كتاب القضاء الإداري، حيث جعلنا شرحه وسطاً فلا هو بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل إيجازاً مختصراً مزوداً بالترقيم لصفحات الموضوعات في الكتاب المنهجي ، وذلك لغرض سهولة الرجوع إليها ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يعود بثوابه لروح أبي الحبيب ، وشقيقتي ومقلة عيني رحمهما الله ، وسائر موتى المسلمين .

تنبيه

أستميحكم عذراً على الأخطاء الإملائية والجوهرية إن وجدت ، وإنما أنا بشر اخطئ واصيب فإن اصبث فمن الله ، وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان .

ختاماً

الشكر موصول للمحامية | زينب السليفاني على إبداء المشورة الراجعة والفكرة الناجحة والرأي السديد فيما يتضمنه هذا الإيجاز من فائدة جامعة وممانعة لفوارس القانون وعماد العدالة .

محمد سعيد
السيد

الباب الأول - مبدأ المشروعية ص ٣ - ٤

مبدأ المشروعية: يعني خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها وجميع تصرفاته.

لذا فإن على جميع السلطات العامة في الدولة، التشريعية، التنفيذية، والقضائية الخضوع للقانون. يتعين على الإدارة ان تأتي أعمالها موافقة للقانون وإلا عدت جميع تصرفاتها غير مشروعة وتستوجب الإلغاء.

إن احترام الإدارة لمبدأ المشروعية يكون من الجانبين **الموضوع والشكلي:**

• **أولاً:-** مبدأ المشروعية في الجانب الموضوعي

• **ثانياً:-** مبدأ المشروعية في الجانب الشكلي

أولاً:- مبدأ المشروعية في الجانب الموضوعي:

مبدأ المشروعية في الجانب الموضوعي: يعني إن أي تصرف يصدر عن الإدارة يجب أن يكون مطابقاً للقواعد القانونية النافذة في الدولة وعليه فإن الجانب الموضوعي يقتضي وجوب إصدار قرارات الإدارة على مقتضى القواعد القانونية، فلا يجوز مخالفتها طالما هي قائمة ولم يتم تعديلها أو إلغائها. وبناءً على ذلك فإن القاعدة القانونية يجب أن تحترم من الجهات الإدارية الأدنى من الجهة التي اصدرتها، فالوزير عليه احترام القواعد التي قررها مجلس الوزراء، كما يجب احترامها من ذات السلطة التي وضعها.

ثانياً:- مبدأ المشروعية في الجانب الشكلي:

مبدأ المشروعية في الجانب الشكلي: يعني أن كل سلطة أو جهة تريد أن تصدر قاعدة قانونية عليها أن تراعي القواعد الصادرة من السلطات العليا.

الفصل الأول - مصادر مبدأ المشروعية: ص ٥

• **المبحث الأول:-** المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية

• **المبحث الثاني:-** المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية

المبحث الأول - المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية

تشمل المصادر المكتوبة أو المدونة لمبدأ المشروعية، وهي:

١. الدستور

٢. التشريع العادي

٣. الأنظمة (اللوائح)

المطلب الأول - الدستور: ص ٧

الدستور:- هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية المنظمة للدولة والتي تبين شكل الحكم فيها، وماهية السلطات العامة من حيث تشكيلها واختصاصاتها وعلاقة بعضها ببعض الآخر وتقريرها لحقوق الأفراد وحررياتهم، وتقع القواعد الدستورية على قمة الهرم القانوني في الدولة.

تعد قواعد الدستور المرجع الأول لمشروعية أعمال الإدارة، وهذا يوجب على السلطات الإدارية ان تلتزم بقواعد الدستور ولا يحق لها مخالفتها في أعمالها وإلا وجب إلغائها والتعويض عما تسببه من ضرر للغير

إن قواعد الدستور يجب أن تكون موافقة لمبدأ المشروعية الذي يكون الدستور مصدره الأول والأساسي

فإذا كان الدستور لا يثير الأشكال في هذا الأمر إلا إن الصعوبة تظهر في معرفة القيمة القانونية لإعلانات حقوق الإنسان وللمقدمات الدساتير

س| ما الآراء التي قيلت في تحديد القيمة القانونية لإعلانات حقوق الانسان؟ ص ٨

١. يرى بعض الفقهاء إن لها قيمة قانونية أعلى من قيمة النصوص الدستورية لأنها تتضمن الأسس التي تقوم عليها قواعد الدستور و لكونها تعد تعبيراً عن إرادة الأمة.

٢. يرى بعض الفقهاء إن لها قوة الزام القواعد الدستورية، وعليه فهي مصدر من مصادر المشروعية.

٣. يرى هذا الفريق إن لها قيمة القوانين العادية، لأنها تنص على بعض الحقوق ولكنها لا ترتقي الى مكانة النصوص الدستورية، ومن ثم يجوز للمشرع أن يتناولها بالتعديل حسب ما يظهر له وعلى وفق ما تلميه المصلحة العامة.

٤. فرق أصحاب هذا الرأي بين نوعين من النصوص التي تحتويها اعلانات حقوق الإنسان

- **النوع الأول:** يتسم بالتحديد ويأتي في صيغة قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر وهو ملزم لسلطات الدولة.

- **اما النوع الثاني:** من النصوص فهي تتضمن مبادئ عامة غامضة غير محددة ولا تعد ملزمة للسلطات العامة في الدولة.

٥. ينكر أصحاب هذا الرأي أي قيمة قانونية وأي الزام لإعلانات حقوق الإنسان فهي برأيهم مبادئ فلسفية غير محددة وغير ملزمة ولا تعد مصدرًا من مصادر المشروعية

س| الفرق بين النصوص التقريرية والنصوص التوجيهية ؟ ص٩

١. **النصوص التقريرية أو القانونية:** تمتاز هذه النصوص بأنها محددة وقابلة للتطبيق الفوري ويستطيع الأفراد المطالبة بتطبيقها من دون تدخل المشرع لتنظيم كيفية التطبيق، وهي قيدًا على إرادة المشرع العادي باحترام ما جاء فيها، كالنص الدستوري الذي يقضي (بوجوب التعويض العادل في حالة نزاع الملكية أو الحرمان منها) وبعبارة أخرى تعد القوانين غير دستورية

٢. **النصوص التوجيهية:** تعتبر نصوص غير محددة لأنها تمثل أهداف يعمل النظام السياسي على تحقيقها، لذا فهي قواعد لا يمكن للأفراد المطالبة بتطبيقها إلا بتدخل المشرع، ومن أمثلتها حق العمل لكل مواطن والحق في المعونة في حالات العجز والمرض والشيخوخة وحق الدخول في الوظيفة العامة.. إلخ.

س| من الذي يلتزم تجاه النصوص التوجيهية ؟ ص٩

يلتزم المشرع العادي تجاهها سياسيًا وقانونيًا

١. **سياسيًا:** أي وجوب تدخل البرلمان لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه النصوص.

٢. **قانونيًا:** أي يتوجب على البرلمان عدم إصدار قوانين مخالفة لهذه النصوص

المطلب الثاني - التشريع العادي: ص١٠

التشريع العادي: هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في حدود اختصاصها المبين في الدستور وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فيه.

- يعد التشريع العادي مصدرًا من مصادر المشروعية مما يحتم على جهة الإدارة ان تحترم قواعده فلا تخرج على مقتضاها
- لكن هذا لا يعني ان الإدارة تلتزم فيما تتخذه من قرارات بكل القواعد القانونية فهي لا تتقيد إلا بالتشريعات التي تتفق وطبيعة الاختصاصات التي تمارسها أي الوظيفة الإدارية
- إذن فهي ليست ملزمة بتطبيق قواعد القانون المدني أو غيره من فروع القانون المتعارضة مع النشاط الإداري
- **الخلاصة** إن ليس كل التشريعات العادية تمثل مصدرًا للمشروعية تجاه الإدارة

س| يعود خضوع الإدارة لأحكام التشريع العادي إلى اعتبارين فما هما؟ ص١١

١. إن الوظيفة التشريعية بطبيعتها تنصرف إلى وضع قواعد عامة مجردة تتولى السلطة التنفيذية تطبيقها من خلال ما تصدره من قرارات تنظيمية أو فردية.
٢. إن القانون يصدر عن ممثلي الشعب وعليه فإن السلطة التنفيذية ملزمة باحترام القانون وعدم مخالفته في جميع أعمالها.

المطلب الثالث - الأنظمة (الوائح) ص١٢

الأنظمة (الوائح): هي تشريعات فرعية تصدرها السلطة التنفيذية.

- الأصل إن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في سن التشريع طبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات إلا أن الواقع العملي حتم التخفيف من حدة هذا المبدأ وذلك بمنح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار نوع جديد من القواعد العامة المجردة يطلق عليها الفقه اسم الأنظمة أو اللوائح .
- تعتبر اللوائح قرارات إدارية لأنها تصدر من حيث الشكل عن السلطات الإدارية في الدولة في حدود اختصاصها المحدد في القانون.
- أما من الناحية الموضوعية فإنها تعد قرارات تنظيمية لأنها تحتوي على قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد.

س| ما هي الاختلافات بين القانون والأنظمة؟

القانون	الأنظمة
يصدر عن السلطة التشريعية.	تصدر عن السلطة التنفيذية.
أعلى مرتبة من الأنظمة.	أدنى مرتبة من القانون.
يستطيع أن يلغي الأنظمة أو يعدلها عدا حالة اللوائح المستقلة.	لا يجوز أن يخالف القانون أو تعدله.
يستطيع المشرع فرض ما يشاء من القواعد القانونية بشرط عدم مخالفتها الدستور.	سلطة التنفيذية حقها في وضع الأنظمة محددًا بنص الدستور والقانون.

س| عدد أنواع الأنظمة مع الشرح ؟ ص ١٣

١. الأنظمة التنفيذية.
٢. الأنظمة المستقلة.
٣. أنظمة الضبط.
٤. أنظمة الضرورة.
٥. الأنظمة التفويضية.

أولاً: الأنظمة التنفيذية: ص ١٤

هي الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية من أجل وضع القوانين التي اقترتها السلطة التشريعية موضع التطبيق

- فهي تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين.
- يمارس مجلس الوزراء اصدار الأنظمة والتعليقات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.. **الفقرة ثالثاً من المادة ٨٠ دستور**
- يشترط لمشروعيتها ألا تتعارض مع احكام القانون التي صدرت استناداً إليه وأن لا يكون من شأنها تعديل أو تعطيل تنفيذ القانون أو الإعفاء من تنفيذه
- كما يشترط ان تكون الأحكام الواردة فيها لازمة لتنفيذ القانون فحسب وأن يصدر النظام من جهة تنفيذية وإلا عد نظاماً غير قانوني.
- ويجب أن يتم تنفيذ هذه الأنظمة بأثر فوري من تاريخ صدورها أي لا يجوز أن تتضمن أثراً رجعياً وإلا كانت غير مشروعة لأنه سيكون هناك مساساً بالحقوق المكتسبة

ثانياً: الأنظمة المستقلة: ص ١٥

الأنظمة المستقلة وهي تلك الأنظمة التي تضعها السلطة التنفيذية بصورة مستقلة عن أي قانون آخر بقصد إنشاء وترتيب المصالح أو المرافق العامة وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية.

- لا يتم إنشاء وتنظيم المرافق العامة إلا بقانون أو بناءً على قانون
- تنص المادة ٨٦ من الدستور "ينظم بقانون، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير"

ثالثاً: أنظمة الضبط: ص ١٦

أنظمة الضبط: هي الأنظمة التي تضعها السلطة التنفيذية لأجل المحافظة على النظام بعناصره المتعددة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة

- فإذا صدرت الأنظمة الضبطية مستهدفةً غرضاً آخر فإنها تعد متجاوزة لنطاقها وبالتالي غير مشروعة.
- تعد أنظمة الضبط من الناحية الموضوعية بمثابة القوانين لأنها عبارة عن قواعد عامة مجردة تنطبق على كل من تتوفر فيه شروط انطباقها.

- أما من حيث الشكل فهي تعتبر أنظمة لصدورها من السلطة التنفيذية.
- من أمثلتها الأنظمة الخاصة بالمرور والأنظمة الخاصة بالمحال العمومية والأنظمة الخاصة بحماية الأغذية والمشروبات وأنظمة الوقاية من الأمراض والأوبئة المعدية
- إن ليس من الدستوري إصدار أنظمة الضبط لعدم جواز تقييد حرية الأفراد وحياتهم إلا بقانون أو بناءً على قانون، وذلك ما نصت عليه المادة ١٥ من الدستور "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة"

رابعاً: أنظمة الضرورة: ص ١٧

أنظمة الضرورة: هي الأنظمة أو القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية في ظروف غير عادية لمواجهة المخاطر الداخلية أو الخارجية التي لا تحمل التأخير كالفن والحروب والاضطرابات السياسية وحالات الاستعجال

- وقد تصدر هذه الأنظمة بشكل مراسيم أو قرارات لها قوة القانون وقد تخرج بها السلطة التنفيذية عن حكم الدستور والقانون لمواجهة الحالات الاستثنائية التي ذكرنا جزء منها أعلاه
- يشترط ألا يتم إصدار مثل هذه المراسيم أو القرارات إلا في حالة غيبة البرلمان كصدور قرار بحله أو إيقافه أو في حالة عطلة.
- ويجب عرض هذه المراسيم أو القرارات على البرلمان في أول اجتماع له بعد عطلته أو تكوينه بعد حله من أجل إقرارها أو تعديلها أو إلغائها فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي مالها من قوة القانون

خامساً: الأنظمة التفويضية: ص ١٩

الأنظمة التفويضية: وهي عبارة عن مراسيم أو قرارات بقوانين تصدر عن السلطة التنفيذية بناءً على تفويض من السلطة التشريعية في مسائل يشترط الدستور صدور قانون بها.

- وتصدر هذه الأنظمة في ظل الظروف استثنائية عادةً ولمدة محددة وفي موضوعات معينة على أن تعرض على البرلمان لغرض اعتمادها.
- تعد هذه الأنظمة مظهرًا من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تساهم بموجبها السلطة التنفيذية بالوظيفة التشريعية.
- يعد التفويض التشريعي ظاهرة منتشرة وبشكل واسع في معظم الدول إلا أن العراق قد خلت دساتيره المتعاقبة من أن يُسمح بإصدار الأنظمة التفويضية
- الخلاصة إن قيام السلطة التنفيذية بإصدار مثل هذه الأنظمة يعد أمرًا مخالفًا للقواعد الدستورية.

المبحث الثاني - المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية: ص ٢١

المصادر غير المكتوبة: هي القواعد غير المكتوبة والتي تعد مكملة للقواعد المكتوبة حيث اعتمدها القضاء الإداري لتصبح لها قوة إلزامية أسوةً بالنصوص المكتوبة وتمثل بـ:

- العرف الإداري.

- المبادئ العامة للقانون.

المطلب الأول - العرف الإداري: ص ٢٢

العرف الإداري: هو مجموعة القواعد غير المكتوبة التي درجت الإدارة على اتباعها في مباشرة نشاط معين بحيث يسود الاعتقاد لدى الإدارة والأفراد بأن هذا السلوك أصبح ملزمًا.

وللعرف الإداري ركنان، هما:

١. الركن المادي: يكون باتباع الإدارة لسلوك معين وبشكل منتظم من دون انقطاع ولمدة كافية لاستقراره.
٢. الركن المعنوي: يعني أن يسود الاعتقاد لدى الجهات الإدارية بإلزامية اتباع السلوك الذي درجت عليه، وإنها صارت قاعدة واجبة الاحترام.

شروط العرف الإداري:

يخضع العرف الإداري إلى عدد من الشروط الأساسية والتي يجب أن تكون مجتمعة لغرض منحه هذه الصفة وتتسم هذه الشروط **بالعمومية والاستمرارية** وعدم مخالفتها لنص تشريع قائم.

وهذه الشروط، هي:

١. **أن يكون العرف عامًا:** يعني ألا يكون الاعتياد مقصورًا على شخص أو أشخاص معينين بالذات، بل أن يكون عامًا، ولا يعني أن يكون الاعتياد شاملًا لكل إقليم الدولة، إذ قد يقتصر على جزء من الإقليم.
٢. **أن يكون العرف مستقرًا:** أي أن يكون قد مضى على استمرارية العمل بالقاعدة العرفية زمن كافٍ يؤكد استقرارها، كما يجب أن يكون ثابتًا أي أن تطبقه الإدارة بصورة منتظمة ودونما انقطاع.
٣. **أن لا يكون العرف قد نشأ مخالفًا لنص قائم:** يجب ألا تكون القاعدة العرفية مخالفة لقاعده قانونية، إذا توافرت هذه الأركان والشروط أصبح ملزمًا وواجب الاتباع ويستطيع القاضي تطبيقه على المنازعات التي تعرض عليه.

أمثلة على العرف الإداري:

- سلوك الموظف أثناء العمل والاحترام المتبادل بين الأعلى والأدنى ودرجات الوظيفة الدنيا والعليا.
- نظام محاسبة الموظفين والعاملين عند التقصير
- التسلم والتسليم والمحافظة على المرفق العام
- العمل بموجب قاعدة بيانات حسب اختصاص العمل والخبرة والمؤهل العلمي

المطلب الثاني - المبادئ العامة للقانون: ص ٢٤

المبادئ العامة للقانون: هي مجموعة المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب وإنما يعمل القضاء الإداري على استنباطها والكشف عنها بحيث يتعين على الإدارة احترامها وإلا كان تصرفها مخالفًا لمبدأ المشروعية الإدارية.

ومن أمثلة هذه المبادئ

المساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التجارة.. إلخ

الفصل الثاني - الاستثناءات أو القيود التي ترد على مبدأ المشروعية: ص ٢٥

- المبحث الأول - السلطة التقديرية للإدارة

- المبحث الثاني - حالة الضرورة

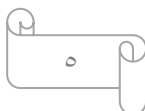
- المبحث الثالث - أعمال السيادة

المبحث الأول - السلطة التقديرية للإدارة: ص ٢٦

- قد يقدر المشرع حاجة الإدارة لقدر من المرونة ولزيد من حرية الحركة في مسألة معينة مانحًا إياها حرية الاختيار بين عدد من الحلول
- فتكون هنا سلطة الإدارة سلطة تقديرية حيث تكون حرة في اتخاذ التصرف المناسب أو الامتناع عنه وكذلك هي حرة في اختيار الوقت الذي تراه ملائمًا للتصرف طالما كان الباحث عليه هو ابتغاء المصلحة العامة ولم يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.

مثاله:

- سلطة الإدارة في إيقاع الجزاءات التأديبية
- وسلطتها في ترقية بعض فئات الموظفين على أساس الكفاءة
- كذلك سلطة الإدارة في الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة



- إذا كانت السلطة التقديرية للإدارة تتضمن توسيعاً لدائرة ونطاق مبدأ المشروعية من دون تجاوز له أو خروج على مقتضاه.
- فإنها تعد في ذات الوقت سلطة خطيرة إذ هي لا تخضع إلى الرقابة الملائمة ولكن رغم خطورة هذه السلطة فإن وجودها يبدو أمراً لا مناص منه
- إذ لا يمكن بحال تقييد نشاط الإدارة بصفة مطلقة وفرض سلوك محدد يتعين عليها أن تتبعه في جميع أوجه نشاطها.

يعود السبب في منح الإدارة هذه السلطة إلى عدد من المبررات، هي:

١. من المتعذر على المشرع أن يحدد للإدارة مقدماً مساراً معيناً تتبعه في مزاولة نشاطها الإداري فهو لا يستطيع أن يتنبأ بالظروف المحيطة بكل تصرف أو ملاساته الأمر الذي يقتضي ضرورة ترك سلطة التقدير للإدارة في تصرفاتها
٢. إن عدم تخويل الإدارة سلطة تقديرية في ممارسة نشاطها يجعل منها أداة صماء لتنفيذ القوانين حرفياً من دون مراعاة ظروف التنفيذ، ومن شأن ذلك أن يُصيب نشاط الإدارة بالجمود والركود ويقضي على قدرة الابتكار والتجديد لديها.
٣. إن منح الإدارة سلطة تقديرية يجب أن لا تفسر على إنها ميزة تستطيع الإدارة أن تتعسف في استعمالها بل هي تقرر مقابل تحملها مسؤولية كبيرة تمكن في سير المرافق العامة بانتظام.

نطاق السلطة التقديرية: ص ٢٨

إن نطاق سلطة الإدارة التقديرية تختلف من عنصر لآخر من عناصر القرار الإداري.

- حيث في ركن الغاية لا مجال للسلطة التقديرية كون غاية القرار الإداري هي الصالح العام.
- كما إنه لا مجال للسلطة التقديرية فيما يتعلق بركن الاختصاص، حيث يحدد القانون دائماً السلطة المختصة بإصدار القرار أو القيام بالعمل الإداري وهو تحديد يجب الإلتزام بعدم الخروج عليه، إلا أنه قد يظهر ضمن قواعد محددة كنفويض الاختصاص.
- أما بالنسبة لركن الشكل فإن الأمر يختلف فيما إذا كان القانون قد فرض شكل معين للقرار الإداري أو تطلب اتخاذ إجراءات محددة، فإذا كان قد فرض شكل معين تكون سلطة الإدارة مقيدة وإذا لم يفرض تكون سلطة الإدارة تقديرية. علماً إن الإدارة يمكنها تجاوز شرط الشكل عند الاستعجال أو الضرورة

أما فيما يتعلق بركن السبب فإن سلطة الإدارة تخضع إلى الاعتبارات الآتية:-

١. **صحة وجود السبب:** إذا كان الأمر يتعلق بسبب القرار الإداري الذي دفع الإدارة للتصرف فإنه لا مجال للسلطة التقديرية حيث يتطلب القانون تحقق مشروعية السبب، وبالتالي تملك الإدارة سلطة منح المشروعية لقرارها المستند إلى وقائع ترى إنها كافية لإصداره.
٢. **التكليف القانوني للوقائع:** إن التكليف القانوني للأفعال المكونة لركن السبب في القرار الإداري هي التي تقرر مدى مشروعيتها حيث إن سلطة الإدارة تبقى مقيدة لكن لها سلطة تقديرية تجاه الوقائع التي تقرر مدى أهميتها في اتخاذها للقرار كما هو الحال في توجيه عقوبة انضباطية لموظف بسبب عدم طاعته لرئيسه الإداري
- أما بالنسبة للمحل وهو الأثر القانوني الذي يترتب على القرار حالاً ومباشرةً فإن للإدارة حرية التدخل والامتناع عن التدخل طالما إن المشرع لم يلزمها بالتدخل عند تحقق بعض الشروط، على أن يكون المحل جائزاً وممكنًا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

حدود السلطة التقديرية: ص ٢٩

إن السلطة التقديرية لا توجد بنفس المدى في جميع تصرفات الإدارة فقد تصل إلى الحد الأقصى وقد تصل إلى الحد الأدنى وقد تكون بين الحدين.

١. السلطة التقديرية في حدها الأقصى
٢. السلطة التقديرية في حدها الوسط
٣. السلطة التقديرية في حدها الأدنى

أولاً: السلطة التقديرية في حدها الأقصى:

- يعني أن يكون من حق الإدارة أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف في الوقت الذي تراه مناسباً لإصدار القرار
- فإذا أصدرته فهي تستطيع اختيار الأسباب التي تبني عليها القرار لأن القانون لا يحدد لها أسباب معينة بالذات في حالة إصدارها للقرار
- ومن أمثلة السلطة التقديرية في حدها الأقصى حالة الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة دون الإقامة العادية.

ثانياً: السلطة التقديرية في حدها الوسط: ص ٣٠

- تمتلك الإدارة في ظل هذه السلطة حرية التصرف أو عدم التصرف فلها سلطة إصدار القرار أو الامتناع عنه وكذلك اختيار الوقت المناسب لإصداره
- ولكنها إذا قررت إصدار القرار فإنه يجب أن يبنى على أسباب محددة
- مثاله كحالة إصدار الإدارة لقرارات بتوقيع الجزاءات تجاه بعض الموظفين
- فهي وإن كان لها سلطة توقيع الجزاء من عدمه إلا إنها إذا قررت إيقاعه بقرار تأديبي كان لزاماً عليها أن تؤسس قرارها على سبب مبرر وهي الحالة الواقعية أو القانونية المبررة للقرار

ثالثاً: السلطة التقديرية في حدها الأدنى:

في ظل هذه السلطة يتحتم على الإدارة التصرف عند توافر أسباب أو شروط معينة يحددها القانون ولكنها تكون حرة في اختيارها للوقت المناسب لإصدار القرار

رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة: ص ٣١

- إن الرقابة القضائية للأعمال الصادرة من الإدارة في حالة السلطة المقيدة لا تحتاج الى عناء، لأن القانون يحيط تصرف الإدارة بعدد من الشروط الشككية والموضوعية مما يسهل على القضاء التحقق منها.
- بعكس حالة السلطة التقديرية فإن القانون لا يفرض عليها وجوب التقييد بقواعد أو شروط محددة في التصرف، فيكون لها حرية التقدير لأن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية وليس قاضي ملائمة أي إنه ينظر إلى مدى مطابقة التصرف للقانون
- رغم ذلك فقد فرض القضاء الإداري رقابته على عنصر الملائمة على سبيل الاستثناء وعلى عنصر المشروعية وذلك في ميدان القرارات المقيدة للحريات وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية للموظفين.

المبحث الثاني - حالة الضرورة (الظروف الاستثنائية) ص ٣٢

حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية وهي التي تعجز القواعد العادية معها عن مواجهة ظروف استثنائية كالحروب والأزمات.

- لذا ففكرة الظروف الاستثنائية تقضي بوجوب قيام الإدارة باتخاذ الاجراءات والقرارات ولو خالفت مبدأ المشروعية المطبق في الظروف العادية
- فتحل المشروعية الاستثنائية محل المشروعية العادية.

س| ما هي شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية؟ ص ٣٣

١. وجود خطر جسيم يهدد النظام العام: يشترط لتحقيق هذا الشرط قيام حالة واقعية غير مألوفة تمثل خطراً جسيماً يهدد النظام العام كالحروب والكوارث الطبيعية
٢. تعذر دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية: القاعدة العامة إن على الإدارة مواجهة الخطر الجسيم طبقاً لقواعد واساليب القانون العادي فإن تعذر درء هذا الخطر بواسطة هذه القواعد يكون لها اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة خروجها على قواعد القانون العادي.
٣. تحقيق المصلحة العامة: إن كان هذا التصرف لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سلامة الدولة والنظام العام عُدت تصرفاً تعسفياً أو إجراءً كيدياً.
٤. تناسب الاجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي: لا يجوز للإدارة أن تتصرف إلا بالقدر الذي يملية الظرف، فالإجراء الاستثنائي يجب أن لا يتجاوز القدر الضروري للتغلب على هذه الظروف وبالعكس ذلك سيدخل تصرفها ضمن نطاق التعسف أو المغالاة.

٥. إنها سلطة الإدارة الاستثنائية بانتهاء الظرف الاستثنائي: أي إذا انتهى الظرف تعين على الإدارة اتباع قواعد المشروعية العادية إذ بعد زوال الظرف تصبح قرارات المخالفة لمبدأ المشروعية خارج حدود الفترة الاستثنائية باطلة.

رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية: ص ٣٤

إن فكرة الظروف الاستثنائية تجعل تصرفات الإدارة غير المشروعة في ظل الظروف العادية مشروعة وقانونية في ظل الظروف الاستثنائية. وتبعاً لذلك فإن هنالك مجموعة من الضوابط والقيود التي تخضع لها تصرفات الإدارة وإلا عدت تصرفاتها قابلة للإبطال لتجاوز السلطة. وهي كما يلي:

- إن الرقابة القضائية تنصب أولاً على عنصر السبب أي التحقق من وجود الظرف الاستثنائي والتأكد من صحة الحالة الواقعية.
- وكذلك التحقق من مبدأ التناسب بين الاجراء المتخذ والظرف الاستثنائي، فإن كان لا يتناسب يلغى القرار الصادر عن الإدارة.
- وتنصب رقابة القضاء الإداري أيضاً على عنصر الغاية في القرارات الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية، أي التأكد من إنها تهدف لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية.

المبحث الثالث - أعمال السيادة: ص ٣٦

أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية التي لا تخضع لرقابة القضاء سواء كان القضاء الإداري أو العادي، فهذه النظرية تمثل خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية .

مصدر نظرية أعمال السيادة:

- بدأت فكرة أعمال السيادة بالظهور بعد سقوط نابليون وعودة الملكية وذلك بسبب خشية المجلس من أن يقوم اصحاب العهد الجديد بحلّه باعتباره احد مخلفات نابليون
- فبدأ المجلس يجمال الحكومة واخذ يُظهر لها من خلال احكامه ادراكه بأن هناك طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ينبغي ان لا تخضع لرقابته لما تتصف به من أهمية خاص تتعلق بالسياسة العامة للدولة وهي بذلك تتميز عن اعمال الادارة العادية
- بمعنى آخر إن مجلس الدولة ابتدع فكرة اعمال السيادة لاسترضاء الحكومة وكسب ثقته وفعلاً قد نجح في ذلك حيث توطدت العلاقة بينه (أي المجلس) والحكومة حتى انتهى الأمر باعتراف المشرع بقانون ١٨٧٢ بحق مجلس الدولة بالقضاء المفوض غير الخاضع للتعقيب أو التصديق من أحد.

تحديد نطاق أعمال السيادة: ص ٣٧

أن معايير التمييز التي وضعها الفقه والقضاء الإداريان ثلاثة يمكن من خلالها تحديد نطاق اعمال السيادة وتمييزها عن اعمال الإدارة العادية وهي

- أولاً: معيار الباعث السياسي
- ثانياً: معيار طبيعة العمل
- ثالثاً: معيار القائمة القضائية

أولاً: معيار الباعث السياسي:

الباعث السياسي: هو العمل الذي تقوم به السلطة التنفيذية بقصد تحقيق أغراض سياسية

- تبعاً لهذا المعيار يعد العمل الذي قامت به الحكومة عملاً من اعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسياً وإن كان الدافع غير سياسي فإنه يعد إدارياً يخضع لرقابة القضاء وقابل للطعن به والإلغاء أو التعويض
- وقد بقي معيار الباعث السياسي قائماً حتى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر

س/ ما هي الانتقادات التي أدت إلى هجر هذا المعيار؟

١. إنه معيار مرن وغير محدود
٢. إنه عمل إداري إذا لم تصفه الحكومة بأنه عمل سيادي
٣. كما إنه معيار بالغ الخطورة إذ انه يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم

ثانياً: معيار طبيعة العمل: ص ٣٨

يقوم هذه المعيار على أن السلطة التنفيذية تقوم بوظيفتين:

١. الوظيفة الحكومية: عندما تمارس السلطة التنفيذية وظيفتها الحكومية تعد الأعمال التي تقوم بها أعمال سيادة.. كإعلان الحرب والمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي.
٢. الوظيفة الإدارية: أما إذا مارست السلطة التنفيذية وظيفتها الإدارية فهي أعمال إدارة ومثالها كل عمل يتعلق بالتطبيق اليومي للقوانين وتنظيم علاقة الأفراد بالإدارة وعلاقة الإدارات المختلفة بعضها البعض الآخر

الانتقاد الذي وجه لهذا المعيار:

يحمل قدراً كبيراً من الغموض والابهام إذ إنه يتعذر وضع حد فاصل بين الأعمال الحكومية والأعمال الإدارية.

ثالثاً: معيار القائمة القضائية:

من أجل الكشف عن أعمال السيادة في الأحكام القضائية، اتجه الفقه لوضع قائمة بأعمال السيادة وتصنيفها في مجموعات محددة وعلى سبيل الحصر.

تتمثل بما يلي: ص ٣٩

- المجموعة الأولى: الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية كالقرارات الخاصة بالانتخابات العامة، كما إنها تضم الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان من حيث وقف جلسات البرلمان أو حله أو دعوته للانعقاد
- المجموعة الثانية: الأعمال التي تتصل بالشؤون الخارجية كالأعمال التي يقوم بها ممثلو الدولة في الخارج فيما يتصل بوظائفهم الدبلوماسية
- المجموعة الثالثة: الأعمال المتصلة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، مثل المفاوضات التي تدور بشأنها وكيفية إبرامها والتصديق عليها.
- المجموعة الرابعة: الأعمال المتعلقة بالحرب، كقرار إعلان الحرب
- المجموعة الخامسة: الأعمال الخاصة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي

موقف المشرع العراقي من نظرية أعمال السيادة: ص ٣٩ - ٤٠

إن مصدر نظرية أعمال السيادة في العراق هو التشريع وليس القضاء كما هو الحال في فرنسا حيث نصت المادة العاشرة من قانون التنظيم القضائي رقم ٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل على أنه "لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة" وكذلك أشارت المادة سابعاً من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ على أنه "لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، وتعد من أعمال السيادة المراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية"

- إلا إن هذا الأمر قد تغير برمته بعد صدور دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥ الذي حظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إداري من الطعن المادة ١٠٠ من الدستور

- وعلى هذا فإنه يمكن الطعن قضائياً بأي عمل أو قرار إداري مما كانت جهة إصداره ومهما علت مرتبة مصدره في الدولة بما في ذلك المراسيم والقرارات المتعلقة بأعمال السيادة

الباب الثاني - وسائل مراقبة المشروعية: ص ٤١

- يعد خضوع الدولة في تصرفاتها لأحكام القانون من المظاهر الأساسية
- وليس المقصود بخضوع الدولة للقانون هو تحديد سلطات معينة فيها وإنما المقصود من ذلك خضوع الدولة بكامل هيئاتها للقانون
- بمعنى إن القانون لا يقيد السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فحسب، بل يقيد الدولة ذاتها في جميع مظاهر نشاطها، سواء كانت تمارس نشاطاً تشريعياً أو نشاطاً إدارياً أو قضائياً
- ولأجل تحقيق نظام الدولة القانونية يجب أن ترتبط تلك القواعد بجزاء منظم يفرض على من يخالفها.

أنواع الرقابة على أعمال الإدارة: ص ٤٢

- **الفصل الأول: الرقابة السياسية**
- **الفصل الثاني: الرقابة الإدارية**
- **الفصل الثالث: الرقابة القضائية**

الفصل الأول: الرقابة السياسية: ص ٤٣

الرقابة السياسية: وهي الرقابة التي تتحقق عندما تقوم سلطة سياسية بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة العامة.

- وتعد هذه الرقابة سياسية من حيث السلطة التي تقوم بها أو من حيث الآثار المترتبة عليها
- فهي تمارس رقابة شاملة على الأعمال والمشروعية والملائمة

تتخذ الرقابة السياسية صورًا مختلفة فقد تتمثل بما يلي:

- **أولاً: الرقابة البرلمانية**
- **ثانياً: رقابة الرأي العام**

أولاً: الرقابة البرلمانية:

الرقابة البرلمانية: وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية والتي يطلق عليها اسم مجلس النواب أو الجمعية الوطنية أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة.

- انط دستور جمهورية العراق الدائم لعام ٢٠٠٥ محمة الرقابة على أداء سلطة التنفيذ إلى مجلس النواب
- حيث تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من خلال السؤال الذي يوجهه أحد النواب إلى مجلس الوزراء أو وزير معين لتوضيح موضوع محدد أو للتحقق من صحة واقعة معينة
- وتُمارس هذه الرقابة أيضًا عن طريق الاستجواب الذي يعني التحقق من سلامة الأداء الإداري وقد ينتهي الأمر إلى طرح الثقة
- حيث يمكن بواسطة ذلك مسائلة الوزراء عند ثبوت وجود الخلل والقصور في ممارستهم لوظائفهم وصولاً إلى تنحية وزير أو أكثر من خلال سحب الثقة أو طرحها .

نص المادة ٦١ سابقاً وثامناً

يُمارس مجلس النواب برقاوته على السلطة التنفيذية وفقاً لما يأتي:

١. **لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللوسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.**
٢. **يجوز خمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.**
٣. **لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبته في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.**
٤. **لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، وبعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، أثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.**
٥. **لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس ٥/١ اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.**
٦. **يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وتعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.**
٧. **لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.**

ثانياً: رقابة الرأي العام:

بعد التقدم الكبير لم يعد البرلمان هو المعبر الوحيد عن الإرادة الشعبية حيث ظهرت إلى الوجود وسائل الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية التي تعبر عن الرأي العام وتمارس بذلك رقابة سياسية على النشاط الإداري.

الفصل الثاني: الرقابة الإدارية: ص ٤٧

الرقابة الإدارية: هي الرقابة التي تقوم فيها الجهات الإدارية ذاتها بمراجعة أعمالها وقد تؤدي تلك المراجعة إلى سحب القرارات أو إلغائها أو تعديلها، وذلك احتراماً لمبدأ المشروعية، مع مراعاة حقوق الأفراد المتولدة عن تلك القرارات.

- وهذه الرقابة لا تقتصر فقط على التأكد من مدى توافق تصرفات الإدارة مع القانون وإنما أيضاً من حيث تناسبها مع الهدف الذي صدرت من أجله فهي رقابة مشروعية وملائمة في نفس الوقت.

تنقسم الرقابة الإدارية الى نوعين:

- أولاً: الرقابة الذاتية التلقائية

- ثانياً: الرقابة بناءً على تظلم

أولاً: الرقابة الذاتية التلقائية:

إن الإدارة وهي تُمارس أوجه نشاطها تلتزم بضرورة احترام مبدأ المشروعية ومن ثم قيامها بمراجعة قراراتها من قبلها مباشرةً أما أن تكون بالرقابة الولاية أو الرقابة الرئاسية

١. **الرقابة الولاية:** وهي أن تراجع الإدارة من تلقاء نفسها القرار الذي صدر عنها فتعيد النظر فيه وتقوم بسحبه أو الغائه أو تعديله أو استبداله بقرار

آخر باستثناء بعض القرارات، وهي تلك القرارات التي ليس لها سلطة عليها بعد إصدارها كـ **لجان تقدير الضرائب ولجان الجمارك ومجالس التأديب**

٢. **الرقابة الرئاسية:** في هذه الصورة يتقدم من صدر بحقه القرار إلى الرئيس الإداري للموظف الذي أصدره أو رئاسة الهيئة، طالباً منه أو منها ممارسة

سلطتها الرئاسية بإلغاء القرار أو تعديله أو سحبه.

إن الرقابة الرئاسية أما تكون سابقة على اتخاذ القرار الإداري أو لاحقة عليه:

- **الرقابة السابقة:** يكون للرئيس الإداري الحق في توجيه المسؤولين وارشادهم من خلال تعليمات يصدرها لهم، ومن لا يطبقها يعتبر مرتكباً خطأً تأديبياً.

- **الرقابة اللاحقة:** يقوم الرئيس الإداري بها من تلقاء نفسه ليراقب ويراجع أعمال المسؤولين، فإذا اكتشف خطأً فيها فإن له إلغائها أو سحبه أو تعديله أو استبدالها بقرارات أخرى.

ثانياً: الرقابة بناءً على تظلم: ص ٤٩

وهي الرقابة التي تمارسها الإدارة على تصرفاتها بناءً على تظلم يرفع إليها من له مصلحة.

- هذا النوع من التظلم لا يحمل الضمان الكافي لحقوق الأفراد وحرياتهم لأن الإدارة فيه تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت، كالذي يقدم تظلم عن قرار صدر من تربية كركوك مثلاً أمام وزارة التربية.

- يعد التظلم الإداري شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء "التظلم الوجوبي" ولا يشترط في التظلم أن يأخذ شكلاً معيناً أو أن يقدم في ميعاد محدد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

- ليكون التظلم محدياً يجب أن تراعى فيه الإجراءات الشكلية وأن يتضمن التظلم بيانات دقيقة محددة عن التصرف موضوع الشكوى. والتظلم الإداري يكون على أنواع عديدة، فقد يوجه إلى متخذ القرار نفسه وهو ما يعرف **بالتظلم الولاية** أو إلى رئيس من اتخذ القرار وهذا هو **التظلم الرئاسي** وقد يوجه التظلم إلى **لجنة مختصة**.

ملحوظة

إن جميع أنواع التظلمات متاحة للفرد من دون حاجة للنص عليها قانوناً إلا في حالة **التظلم الوصائي** لا يمكن اللجوء إليه إلا بموجب نص قانوني.

تنقسم التظلمات إلى ثلاثة أنواع، وهي: ص ٥٠

- **أولاً:** التظلم الولائي
- **ثانياً:** التظلم الرئاسي
- **ثالثاً:** التظلم إلى لجنة
- **رابعاً:** التظلم الوصائي

أولاً: التظلم الولائي:

التظلم الولائي: وهو التظلم الذي يتقدم به المتضرر من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته موضحاً فيه المخالفات التي ينطوي عليها هذا التصرف طالباً منها إعادة النظر في قرارها فيعمد مُتخذ القرار إلى سحب قراره أو تعديله أو استبداله بغيره

- يتميز التظلم الولائي بإمكانية ممارسته من قبل الفرد لأكثر من مرة إذ لا يوجد ما يحدد ممارسته بعدد من المرات.

ثانياً: التظلم الرئاسي:

التظلم الرئاسي: هو أحد أنواع الرقابة الرئاسية إذ يتمتع الرئيس الإداري وفق هذا المبدأ بسلطة واسعة تجاه مرؤوسيه

- ويقدم هذا التظلم إلى الرئيس الإداري للموظف الذي اصدر القرار مبيئاً فيه الأخطاء التي وقع فيها المرؤوس، طالباً منه تعديل القرار أو إلغائه
- وقد يحقق هذا التظلم للمتضرر من القرار بُغية وحاجة مُلحة، لأن الرئيس الإداري يتمتع بسلطة حقيقية على أعمال المرؤوسين لاسيما في النظام الإداري المركزي.

إن التظلم الرئاسي قد يكون بدرجات متعددة أو بدرجة واحدة:

١. **التظلم الرئاسي متعدد الدرجات:** هو التظلم بقوة القانون حيث يستطيع المتظلم من القرار الإداري اللجوء إلى درجات متعددة في السلم الإداري فالمتضرر من قرار أصدره القائم مقام يستطيع التظلم منه أمام المحافظ ثم أمام وزير الداخلية
٢. **التظلم الرئاسي بدرجة واحدة:** يتم هذا النوع من التظلم أما بموجب نص في القانون يقرر الحق في التظلم كما لو اصدر المحافظ قرار برفض تأسيس جمعية تعاونية إذ يجوز التظلم من هذا القرار امام وزير الداخلية، وأما ينبع من طبيعة نظام تدرج الوظيفة الإدارية الذي يتيح للرئيس الإداري سلطة واسعة على أعمال مرؤوسيه.

ملحوظة

إن التظلم الرئاسي بدرجة واحدة يعد القاعدة العامة في حين أن التظلم الذي مصدره القانون يمثل الاستثناء.

ثالثاً: التظلم إلى لجنة:

- توجد في نطاق الإدارة لجان متعددة يحدد القانون تشكيلاتها واختصاصاتها تتولى مهمة النظر في تظلمات الأفراد من التصرفات غير المشروعة للجهات الإدارية وتقوم بالفصل بالتظلمات دون الرجوع إلى الرئيس الإداري
- وهي أفضل من الطريقتين السابقتين لأنها تمثل ضمانة أكثر فعالية في بحث صحة القرارات المتظلم منها، فهي تمثل اسلوباً وسطاً بين الإدارة القاضية ونظام المحاكم الإدارية.
- ويرجع تفصيل نظام اللجان إلى تشكيلها حيث تشكل من عناصر ذوي خبرة عالية وكفاءة متخصصة مع تعدد الأعضاء فيها مما يؤدي إلى تعدد جهات النظر وهو مالا يتوفر في حالتي التظلم الولائي والتظلم الرئيسي

رابعاً: التظلم الوصائي: ص ٥٢

التظلم الوصائي: هو التظلم الذي لا يمكن اللجوء إليه إلا بنص قانوني

- هذا التظلم يكون أمام الجهة التي تمتلك الوصاية على جهة معينة، فإذا حصل أن قامت هيئات عامة لها استقلال مالي وإداري في تسيير شؤونها بعمل أو امتنعت عن عمل مخالفةً بذلك الهدف الذي أنشأت لأجله أو خالفت به النصوص التشريعية، أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط الذي تقوم به، فإنه يحق للمتضرر التظلم أمام السلطة التي تملك الوصاية عليها.

- وهذا النوع من التنظيم الإداري يكون مصدره نص القانون ووثيق الصلة بنظام الإدارة اللامركزية إذ تمارس الهيئات اللامركزية حرية في اتخاذ القرارات، لكنها تخضع استثناءً لرقابة السلطة المركزية
- س/ قارن بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية ؟ ص ٥٢ - ٥٣

الرقابة القضائية	الرقابة الإدارية
تمارس من قبل المحاكم.	تمارس من قبل السلطات الإدارية.
تتحرك بدعوى يقدمها المتضرر.	عادةً ما تحرك الدعوى تلقائيًا.
تقتصر على رقابة المشروعية إلا في حالات معينة أشرنا إليها سابقًا.	الرقابة الإدارية أوسع لأنها تشمل رقابة المشروعية ورقابة الملائمة.
الطعن القضائي نفقته أكثر وإجراءاته أكثر صعوبة.	التظلم أمام الإدارة يتم بغير نفقات ووفق إجراءات وشكليات أكثر سهولة.
الرقابة القضائية أقل فاعلية	الرقابة الإدارية فاعليتها أكثر.
القرار القضائي يتضمن آثار لا يتضمنها القرار الإداري.	لا تتضمن الرقابة الإدارية جميع آثار القرار القضائي، كحجية الشيء المحكوم به.

الفصل الثالث الرقابة القضائية: ص ٥٤

الرقابة القضائية: هي الرقابة التي تبشر من خلالها السلطة القضائية ممثلة بمحاكمها وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها مراقبة أعمال الإدارة.

- تعد الرقابة القضائية من أكثر أنواع الرقابة ضمانًا لحقوق وحرريات الأفراد نظرًا لما تنطوي عليه من نزاهة واستقلال عن أطراف النزاع، الأمر الذي يكفل للمتقاضين صيانة حقوقهم وحمايتهم من تعسف الإدارة.
- الفصل في الخصومات تطرح أمام القضاء وتخضع لقواعد وإجراءات لا مثيل لها في الأنواع الأخرى للرقابة.
- ترمي الرقابة القضائية إلى تحقيق هدفين يمثل الأول في حماية حقوق الأفراد وحررياتهم والثاني في تقويم الإدارة وجباها على احترام القانون والخضوع لسلطانه.

س/ ما هي أنواع أنظمة القضاء؟

- أولاً: نظام القضاء الموحد
- ثانيًا: نظام القضاء المزدوج

أولاً: نظام القضاء الموحد: ص ٥٥

نظام القضاء الموحد: وهو النظام الذي يقوم على أساس وجود جهة قضائية واحدة في الدولة هي جهة القضاء العادي إذ تتمتع بولاية عامة وشاملة في حل المنازعات.

- إن المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفًا فيها تختص بها نفس الجهة القضائية التي تتولى أصلاً حل المنازعات التي يكون الأفراد أطرافًا فيها.
- كما إن هذه المحاكم تطبق في شأن المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها القواعد القانونية ذاتها التي تطبقها عادةً في شأن المنازعات التي تدور بين الأفراد.
- يسود نظام القضاء الموحد في انكلترا وأمريكا وبعض الدول الأخرى.

مزايا القضاء الموحد

١. توجد جهة قضائية واحدة تطبق أحكام قواعد المشروعية على الجميع من دون تفرقة بين الحكام والمحكومين.
٢. يكفل حماية الحقوق والحريات الفردية.
٣. مساواة الإدارة بالأفراد وعدم تمتعها بأي امتياز حيث تخضع لذات القاضي.
٤. يتميز بالبساطة وعدم التعقيد حيث توجد جهة قضاء واحدة تفصل في كل المنازعات.

أما عيوب القضاء الموحد فهي:

١. لا يراعي هذا النظام طبيعة المنازعات الإدارية حيث إنها تختلف عن طبيعة المنازعات الفردية من حيث الهدف، فالإدارة هدفها تحقيق الصالح العام، بينما يهدف الأفراد لتحقيق مصالحهم الشخصية
٢. يسمح بالتدخل في شؤون الإدارة من خلال توجيه الأوامر والنواهي وتعديل قراراتها، مما يجعل الإدارة خاضعة لسيطرة القضاء وبالنتيجة يؤدي إلى عرقلة أعمالها، الأمر الذي يمثل خروجاً على وظيفة القاضي لأن القاضي يحكم ولا يدير
٣. لا يعطي أي سلطة تقديرية للإدارة مع إنها تهدف لتحقيق المصلحة العامة
٤. لا يكفل من الناحية العملية الحماية الكافية للحقوق والحريات العامة، كما إن قسماً من أعمال الإدارة تخرج عن رقابة القضاء نتيجة وجود تشريعات تمنع النظر فيها.

مدى رقابة القضاء على أعمال الإدارة في ظل القضاء الموحد: ص ٥٧

تظهر سلطة القضاء في انكلترا والتي هي مهد النظام القضائي الموحد من خلال ما يأتي

١. **رقابة الإلغاء:** تتمتع المحاكم برقابة عنصر الملائمة وعنصر المشروعية للقرارات وإلغاء المخالف منها لقاعدة عرفية أو نصوص مكتوبة، فسلطة القاضي الإنكليزي شبيهة بالسلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس الإداري تجاه تصرفات رؤوسيه، علماً إن دعاوى الإلغاء لا تقام تجاه الدولة وإنما تجاه الموظفين بصفة شخصية، القاعدة الدستورية العرفية في انكلترا تقضي بأنه "طالما إن الملك لا يخطئ فلا يمكن أن ينسب الخطأ إلى الدولة"
 ٢. **رقابة التعويض:** يقصد به تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء التي تقع من موظفيها مما يترتب حقاً للأفراد في التعويض عما أصابهم من أضرار وهذه المسؤولية قد تنتج عن قرار غير مشروع أو عقد إداري أو عمل خاطئ سببه الإدارة.
- كانت القاعدة في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم جواز مسألة الدولة بالتعويض عن أخطاء موظفيها لاندماج الدولة في التاج الذي يعد معصوم من الخطأ
- إضافةً لذلك إن العلاقة بين الإدارة والموظف هي ذات طبيعة عقدية وليس تنظيمية تأخذ صورة الوكالة، لأن الموكل لا يسأل عن أعمال وكيله إلا في حدود عقد الوكالة المبرم بينهما، رغم ذلك فقد ورد على قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها بعض الاستثناءات وهي:

١. تقرير مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها
٢. تقرير المشرع لمسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها التابعين للسلطة المركزية

ثانياً: نظام القضاء المزدوج: ص ٥٩ - ٦٠

النظام القضائي المزدوج: وهو النظام الذي تتولى الوظيفة القضائية فيه جهمتان قضائيتان مستقلتان، هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري.

- تختص جهة القضاء العادي في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الإدارة إذا ظهرت في العلاقة القانونية باعتبارها فرداً عادياً
- تختص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تقوم بين الإدارة والأفراد بوصفها سلطة عامة أو بين الأشخاص العامة بعضها ببعض.
- تتألف جهة القضاء العادي من مجموع المحاكم العادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وعلى قمتها توجد محكمة التمييز
- يتألف القضاء الإداري من مجموع المحاكم الإدارية وعلى رأسها مجلس شورى الدولة.

- كما يتميز نظام الازدواج القضائي بضرورة وجود هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات بين جهتي القضاء العادي والإداري وهي محكمة التنازع أو هيئة تنازع الاختصاص

ختامًا

أصبح العراق من دول القضاء المزدوج عندما صدر قانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩

س | ما هي مزايا وعيوب نظام القضاء المزدوج؟ ص ٦١ - ٦٢

من مزاياه:

١. إن هذا القضاء يكون هو الأقدر على حل المنازعات التي تعرض عليه وتكون محل خلاف بين الإدارة والأفراد، وذلك بحكم التخصص من ناحية وبحكم معرفته بأوضاع الإدارة واساليبها من ناحية أخرى.
٢. عن طريقه يمكن التوفيق بين المصلحة العامة وبين مصالح الأفراد المتمثلة في حماية الحقوق والحريات العامة.

أما عيوب هذا النظام، فهي:

١. يرى البعض بأنه لا يكفل مبدأ المشروعية، لأن القضاء الواحد هو الذي يضمن خضوع الجميع لقانون واحد يطبقه قاضي واحد من دون تفرقة بين الافراد وبين الإدارة، والرد على ذلك هو إن مبدأ المشروعية يتطلب فقط خضوع الجميع لأحكام القانون من دون أن يستلزم بالضرورة وحدة القضاء أو وحدة القانون المطبق وهو بهذا لا يتعارض مع مبدأ المشروعية.
٢. يؤخذ عليه إنه يؤدي إلى ظهور مشكلة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري سواء كان التنازع إيجابيًا حيث تتمسك كل جهة بنظر الدعوى أم كان التنازع سلبيًا وذلك عند امتناعهم عن نظر الدعوى بحجة عدم الاختصاص، لكن يمكن حل هذه المشكلة بتحديد اختصاص كل جهة تحديدًا دقيقًا، وإيجاد محكمة مستقلة تتولى حل منازعات الاختصاص ومنع تناقض الأحكام.
٣. ويؤخذ عليه إنه نظام يؤدي إلى محاباة الإدارة على حساب الأفراد، والواقع إن القانون الإداري لم يوضع لمحاباة الإدارة على حساب الأفراد، بل هو قانون روعيت فيه المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، وليس امتيازًا لها.

س | ما هي خصائص القضاء الإداري؟ ص ٦٣ - ٦٤

للقضاء الإداري عدد من الخصائص يميزها عن القضاء العادي، وهي:

١. رقابة القضائي الإداري
٢. لا رقابة للقضاء الإداري على الملائمة
٣. القضاء الاداري لا يحل محل الإدارة في الاختصاص

أولاً: رقابة القضائي الإداري:

- لا يملك القاضي الإداري سوى الحكم بمشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة أو عدم مشروعيتها، فيقضي بإلغائها إذا كانت غير مشروعة، وقد تمتد سلطة القاضي إلى إلغاء القرار أو تعديل القرار والحكم بالتعويض للمتضررين من قرارات الإدارة.

ثانيًا: لا رقابة للقضاء الإداري على الملائمة:

- إن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية وليس قاضي ملائمة، فالإدارة هي التي تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل طالما إن القرار لم يشوبه عيب في انحراف السلطة، إلا إن القضاء الإداري يمكنه بحث عنصر الملائمة عندما يتعلق الأمر بقرارات مقيدة للحرية وتناسب الجزاء مع خطأ الموظف.

ثالثًا: القضاء الإداري لا يحل محل الإدارة في الاختصاص:

- إن هذه الخاصية تعني أن القضاء الإداري يقضي ولكنه لا يدير، أي لا يكون بمقدوره التدخل في شؤون الإدارة ورسم الاتجاه العام في مزاولة نشاطها، ولا يستطيع إصدار القرارات ولا يوجه لها أمرًا بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

الباب الثالث - تنظيم القضاء الإداري: ص ٦٥

يقوم القضاء الإداري على عنصرين أساسيين، هما:

- **أولاً:** وجود محاكم مستقلة عن القضاء العادي: يعني ضرورة إنشاء هيكلية قضائية تبدأ بالمحاكم الإدارية التي تخضع أحكامها إلى محاكم إدارية من ثم وجود محكمة عليا تنتظر بصحة الأحكام الصادرة بصفتها التمييزية
- **ثانياً:** وجود قواعد قانونية مستقلة عن قواعد القانون الخاص: إن استقلال قواعد القانون الإداري تعد نتيجة لوجود محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي لأن هذه القواعد لا تكون وليدة إرادة المشرع حصراً بل كان للقضاء الإداري بصفته قضاءً انشائياً دوراً مهماً في هذا الإطار.

• **الفصل الأول - تنظيم القضاء الإداري في فرنسا**

• **الفصل الثاني - تنظيم القضاء الإداري في مصر**

• **الفصل الثالث - تنظيم القضاء الإداري في العراق**

الفصل الأول - تنظيم القضاء الإداري في فرنسا: ص ٦٦

أولاً: مجلس الدولة الفرنسي: ص ٦٨

يتولى مجلس الدولة وظيفة مزدوجة فهو **المستشار الإداري** للدولة و**القاضي الإداري** لها بنفس الوقت.

- **أعضاء المجلس:** يعد مجلس الدولة هيئة مستقلة يرأسها رئيس الوزراء ويحل محله وزير العدل عند غيابه، وهذه الرئاسة شرفية أما الرئاسة الفعلية فيتولاها نائب رئيس مجلس الدولة.

يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يتدرجون على النحو الآتي:

١. **نائب رئيس مجلس الدولة**، ويحتل أعلى وظائف المجلس وهو الرئيس الفعلي له.
٢. **رؤساء الأقسام وعددهم خمسة ورئيس مساعدين للقسم القضائي.**
٣. **المستشارون العاديون:** ويتم اختيار ثلثي هؤلاء عن طريق الترقية من بين نواب المجلس ويجوز تعيين الثلث الباقي من خارج المجلس
٤. **المستشارون غير العاديين:** تختارهم السلطة التنفيذية من بين ذوي الكفاءات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة عامين من نهاية المدة السابقة، وليس لهم ممارسة الاختصاصات القضائية للمجلس
٥. **النواب:** يعين ثلاثة أرباعهم عن طريق الترقية من بين مندوبي الدرجة الأولى أما الربع الباقي فيجوز تعيينه من خارج المجلس ويختار من بين النواب سكرتير لمجلس الدولة يتولى الأعمال الإدارية فيه
٦. **مفوضو الحكومة أمام القسم القضائي بالمجلس:** يتم اختيارهم من بين النواب وهم لا يمثلون الحكومة، يقومون بدراسة المواضيع المطروحة أمام المجلس من ناحية الوقائع والقانون.
٧. **المندوبون:** وهم على درجتين، مندوبون من الدرجة الثانية ويشغلون أولى درجات السلم الإداري بالمجلس، ويعينون من خريجي مدرسة الإدارة الوطنية ومنسوبون من الدرجة الأولى يعينون عن طريق الترقية من بين مندوبي الدرجة الثانية

أقسام المجلس الفرنسي: ص ٦٩

يتكون مجلس الدولة من قسمين هما:

القسم الإداري للفتوى والتشريع والقسم القضائي.

أولاً: القسم الإداري للفتوى والتشريع:

يختص القسم الإداري بموضوعين

١. **الاختصاص التشريعي:** يقوم القسم الإداري بموجب هذا الاختصاص بصياغة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، وكذلك مشروعات المراسيم الجمهورية التي لها قوة القانون وصياغة مشروعات اللوائح الإدارية الهامة.
٢. **الاختصاص الافتائي:** هو إبداء القسم الإداري الفتاوى والاستشارات في المسائل التي تطلبها منه الوزارات والأصل أن الإدارة غير ملزمة بأخذ رأي المجلس ولكن القانون قد يلزمها بذلك.

ثانياً: القسم القضائي:

يتولى الفصل في المنازعات والاختصاصات القضائية لمجلس الدولة وكما يلي:

١. اختصاصات المجلس بوصفه محكمة أول وآخر درجة: يقصد بها أن الأحكام التي يصدرها المجلس في هذه الحالات تعد بآلة لا يقبل الطعن فيها بأي وجه من الوجوه كدعوى الإلغاء ضد القرارات اللأئحة الصادرة من الوزراء
٢. اختصاص مجلس الدولة بوصفه محكمة استئنافية: يعني هذا الاختصاص إن أحكام المحاكم الإدارية يطعن فيها أمام مجلس الدولة باعتباره جهة استئنافية.
٣. اختصاص مجلس الدولة بوصفه محكمة تمييز: يعد مجلس الدولة محكمة تمييز بالنسبة لجميع المحاكم الإدارية التي لا تخضع أحكامها للطعن استئنافاً أمامه.

ثانياً المحاكم الإدارية: ص ٧٠

- نشأت المحاكم الإدارية في فرنسا تحت اسم مجالس المحافظات وكان لكل محافظه مجلس يرأسه المحافظ ويتولى وظيفه مفوض الحكومة السكرتير العام للمحافظات فضلاً عن عدد من المستشارين
- تم صدرت مراسيم أدخلت بعض التعديلات كأبعاد المحافظ وسكرتير المحافظ عن الإدارة وتقليص عدد المحاكم وإحاطة أعضائها بقدر مناسب من الضمانات
- أما بالنسبة لاختصاص المحاكم الإدارية فهو اختصاص مزدوج حيث يتضمن الافتاء و الاختصاص القضائي.

ثالثاً المحاكم الإدارية الاستئنافية: ص ٧١

- نتيجة لزيادة عدد القضايا المعروضة أمام مجلس الدولة اضطر المشرع الفرنسي إصدار قانون في ٣١ كانون الأول عام ١٩٨٧ يقضي بإنشاء خمس محاكم استئنافية موزعة على خمسة أقاليم رئيسية
- ويرأس كل محكمة مستشار سواء من مجلس الدولة أو من المحاكم الإدارية أو من المحاكم الاستئنافية
- وتختص المحاكم الاستئنافية بنظر الطعون الاستئنافية ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ونص المشرع على أن أحكام المحاكم الاستئنافية يمكن الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة، وليس لها أية اختصاصات استشارية.

الجهة المختصة بالفصل بين القضاء الإداري والعادي وحالات تنازع الاختصاص:

إن ازدواجية النظام القضائي الفرنسي وانعدام النص الصريح المحدد للاختصاص تشير التنازع حول اختصاص كل من القضاء الإداري و القضاء العادي. ويأخذ هذا التنازع ثلاث صور:

١. التنازع الإيجابي: هو أن تدعي جهتي القضاء اختصاصها في حسم النزاع
 ٢. التنازع السلبي: أن تحكم كل جهة من جهتي القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
 ٣. تعارض الأحكام: قد تعارض الأحكام التي تصدر من القضائيين في موضوع واحد وهو ما يؤدي إلى إنكار العدالة.
- ولحل مثل هذه المسائل أنشأ المشرع الفرنسي محكمة التنازع وجعل من اختصاصها الفصل في حالات التنازع على الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي.

محكمة التنازع: ص ٧٣

محكمة التنازع: هي المحكمة المختصة بالفصل بالنزاع على الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي.

تشكيل محكمة التنازع:

شكل المشرع الفرنسي محكمة التنازع على النحو الآتي:

١. وزير العدل ويتولى رئاسة المحكمة بحكم القانون
٢. ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة يختارهم زملائهم بالانتخاب
٣. ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز ينتخبون أيضاً من قبل زملائهم
٤. عضوان أصليان يتم انتخابهما من الأعضاء السبع المذكورين إضافةً إلى عضوين احتياط يتم انتخابهم بالطريقة نفسها.

أما محكمة التنازع في العراق

فقد أشار قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شوري الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ على هذا الجهاز من خلال هيئة تسمى **هيئة تنازع الاختصاص** مكونة من سبعة أعضاء:

١. رئيس محكمة التمييز رئيسًا
 ٢. ثلاثة من أعضاء محكمة التمييز يختارهم رئيس محكمة التمييز
 ٣. ثلاثة من أعضاء مجلس شوري الدولة يختارهم رئيس مجلس شوري الدولة
- وقد اعطى القانون العراقي لهذه الهيئة صلاحية البت بتنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي ويكون قرارها الصادر بالاتفاق أو الأكثرية باثًا وملزمًا

اختصاص محكمة التنازع الفرنسية: ص ٧٤

تختص بالفصل في التنازع على الاختصاص سواء أكان إيجابيًا أم سلبياً أو برفع التناقض بين الأحكام. ونعرض فيما يلي لكل من هذه الحالات:

• أولاً: أحوال تنازع الاختصاص

• ثانياً: حالة صدور حكيم نهائين متعارضين

أولاً: أحوال تنازع الاختصاص:

قد يكون التنازع بين القضاءين تنازعا إيجابيا وقد يكون تنازعا سلبيا

١. **التنازع الإيجابي:** لا يكون إلا لجهة الإدارة وحدها حق الدفع بعدم الاختصاص ويتم ذلك بتقديم الشخص الإداري إلى المحكمة العادية بالدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع المعروض أمامها، فإذا رفضت يحق له إثارة التنازع أمام محكمة الاختصاص التي ستصدر قراراً أما بتقريرها الاختصاص للمحكمة الإدارية أو للمحكمة العادية كما يجب أن يتم الدفع أثناء نظر الدعوى فإذا فصل فيها القضاء العادي بحكم نهائي عندها يستحيل إثارة هذا الدفع إلا إنه يبقى للشخص الإداري طريق آخر حيث يمكن له إثارته أمام محكمة الاستئناف التي ستقرر فيما إذا كان الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري أو للقضاء العادي.
٢. **التنازع السلبي:** يظهر التنازع السلبي في حالة امتناع كل من جهتي القضاء الإداري والعادي بنظر ذات النزاع ويشترط في التنازع أن يكون هنالك حكيم صادرين من جهة القضاء العادي والإداري يقضيان كلاهما بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ويشترط أيضاً الوحدة في النزاع والموضوع والأطراف أمام جهتي القضاء.

ثانياً: حالة صدور حكيم نهائين متعارضين: ص ٧٥ - ٧٦

تظهر هذه الصورة عندما تقوم كل جهة من جهتي القضاء العادي والإداري بإصدار حكم نهائي في ذات الموضوع يتعارض مع الحكم الآخر قد تدارك المشرع الفرنسي هذه الحالة الخاصة فصدر قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٢ الذي نص على حالة التنازع القائمة على وفق عدد من الشروط، هي:

١. وجود دعوتين تستقل كل منهما عن الأخرى وتكونا مع ذلك متحدتين من حيث الموضوع والوقائع.
٢. يتعين على كل جهة قضائية من جهتي القضاء أن تقضي في موضوع النزاع المعروض عليها، لا أن تقضي كل جهة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
٣. أن يحصل المدعي على حكيم نهائين يصدر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري.
٤. أن يصدر حكيمان متعارضان من جهتي القضاء الإداري والعادي بحيث يؤدي هذا التعارض إلى إنكار العدالة.

الفصل الثاني - تنظيم القضاء الإداري في مصر: ص ٧٧

- انتقلت مصر من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج بعد صدور القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الذي أنشأ مجلس الدولة المصري، وقد منح هذا القانون مجلس الدولة سلطة القضاء المفوض منذ البداية
- ولكن اختصاصات المجلس كانت مقيدة لا تشتمل على المنازعات الإدارية جميعها إلا أن بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ توسعت اختصاصات تدريجياً حتى أصبحت تنصب على جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثنى منها بنص صريح.

تشكيل مجلس الدولة المصري:

يتألف مجلس الدولة المصري حسب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ من طائفتين من الموظفين

الأولى: تشمل أعضاء المجلس وهم الموظفون الفنيون

الثانية: تشمل طائفة الموظفين الإداريين ولا ينطبق عليهم صفة الأعضاء في المجلس

- تتألف عضوية المجلس من رئيس المجلس الذي يتم اختياره من بين نواب المجلس ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة الجمعية العمومية للمجلس كما يشرف على أعمال اقسام المجلس وتوزيع العمل بينها والإشراف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس.. إلخ.
- أما نواب رئيس مجلس الدولة فيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- أما المستشارون والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

اقسام مجلس الدولة المصري: ص ٧٨

يتألف مجلس الدولة من الاقسام الآتية:

• **أولاً: القسم القضائي**

• **ثانياً: قسم الفتوى والتشريع**

أولاً: القسم القضائي:

يتكون هذا القسم مما يأتي:

١. المحكمة الإدارية العليا: تعتبر أعلى هيئة في القسم القضائي فهي المعقب النهائي على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، كما يقتصر اختصاصها بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ولها الفصل في الطعون التي يرفعها أعضاء مجلس الدولة في القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية
٢. محكمة القضاء الإداري: تعد صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية، وهي تنظر في هذه المنازعات باعتبارها محكمة أول درجة فضلاً عن ذلك فهي تنظر في المنازعات باعتبارها محكمة استئناف وذلك عند الفصل في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
٣. المحاكم الإدارية: أنشأها المشرع المصري لتخفيف العبء عن كاهل محكمة القضاء الإداري، وتختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين من المستويين الثاني والثالث وفي المنازعات الناشئة عن العقود إذا لم تتجاوز أقيامها ٥٠٠ جنيه.
٤. المحاكم التأديبية: تتكون من نوعين، محاكم تأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادهم، ومحاكم تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث ومن يعادهم، تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتأديب الموظفين ومراقبة السلطة التأديبية وبعض المسائل المتفرعة عن التأديب.
٥. هيئة مفوضي الدولة: تتكون من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين وتختص بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وتحضير الدعوى وتبنيها للمرافعة وعرض تسوية للزراع على الخصوم والطنن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

ثانياً: قسم الفتوى والتشريع:

يضم مجلس الدولة إضافة الى القسم القضائي قسمين أحدهما للفتوى والآخر للتشريع

١. قسم الفتوى: يتولى هذا القسم مهمة إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تهم جهات الإدارة، علماً بأنها ليست ملزمة فإن آراء قسم الفتوى استشارية لجهة الإدارة لها ان تأخذ بها أو تخالفها.
٢. قسم التشريع: يشكل من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويتولى هذا القسم إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة التشريعية كما يتولى مهمة الصياغة القانونية لها.

الفصل الثالث - تنظيم القضاء الإداري في العراق: ص ٨١

- بدأ تنظيم القضاء الإداري في العراق منذ عام ١٩٨٩ حيث أنشأ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة محكمة القضاء الإداري، وأعاد تنظيم مجلس الانضباط العام وجعله هيئة من هيئات مجلس شورى الدولة.

- **وخول المحكمة والمجلس اختصاصات النظر في بعض المنازعات التي قد تثور بين الإدارة والأفراد، وبذلك أصبح من الممكن الحديث عن قيام قضاء إداري في العراق إلى جانب القضاء العادي.**
- **يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصًا استشاريًا، كما يختص بمراجعة مشروعات القوانين للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية.**
- **بعد محاولات عديدة انتهت جميعها بإصدار القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ الذي أنشأ مجلس شورى الدولة في العراق وجعل اختصاصاته استشارية فحسب.**
- **ثم توجت المحاولات السابقة بصدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ الذي جعل اختصاصات مجلس شورى الدولة قضائية واستشارية.**
- **كما صدر في إقليم كردستان - العراق، القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٨ الذي أنشأ مجلس الشورى لإقليم كردستان وجعل اختصاصاته استشارية وقضائية**

تحدث فيما يأتي عن تنظيم القضاء الإداري العراقي في ثلاث مباحث:

- **المبحث الأول - تنظيم مجلس شورى الدولة**
- **المبحث الثاني - اختصاصات مجلس شورى الدولة**
- **المبحث الثالث - القضاء الإداري في إقليم كردستان - العراق.**

المبحث الأول - تنظيم مجلس شورى الدولة: ص ٨٣

حدد القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ كيفية تنظيم مجلس شورى الدولة في العراق وارتباطه إداريًا بوزارة العدل.

المطلب الأول - أعضاء مجلس شورى الدولة: ص ٨٤

أعضاء مجلس شورى الدولة: هم الموظفون الفنيون في المجلس من دون الموظفين الإداريين.

- **يتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن ١٢ ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.. مادة أولى من قانون رقم ١٠٦**
- **وعلى ذلك فإن أعضاء مجلس شورى الدولة هم:**

● **أولاً: رئيس مجلس شورى الدولة**

● **ثانياً: نواب رئيس مجلس شورى الدولة**

● **ثالثاً: المستشارون**

● **رابعاً: المستشارون المساعدون**

أولاً: رئيس مجلس شورى الدولة:

- **لمجلس شورى الدولة في العراق رئيسًا خاصًا به، يعين بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة دون أن يتوقف ذلك على ترشيح أو اقتراح وزير العدل حسبما قضت بذلك المادة ٢٢ المعدلة من القانون.**
- **يتولى رئيس المجلس رئاسة الهيئة العامة وهيئة الرئاسة ومجلس الانضباط العام ويجوز له ان يترأس جلسات الهيئة الموسعة، كما يعود له أمر إحالة مشروعات القوانين والقضايا المعروضة على المجلس إلى إحدى الهيئات المتخصصة لدراستها وإبداء الرأي فيها وهو الذي يتولى تعيين الهيئة الموسعة.**
- **كما يتولى إحالة ما تنجزه إحدى الهيئات إلى الهيئة العامة لمناقشته.**
- **وقد منحه القانون حق اختيار ثلاثة من أعضاء المجلس ليكونوا أعضاء في الهيئة المختصة بنظر النزاع في الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية.**

ثانياً: نواب رئيس مجلس شورى الدولة:

- **لرئيس نائبين بدرجة مستشار يتم تعيينها بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة**

- يتولى اقدمهما رئاسة الهيئة العامة في حالة غياب الرئيس ويجوز أن يتولى أحد نواب الرئيس رئاسة الهيئة الموسعة ورئاسة مجلس الانضباط العام

ثالثا: المستشارون: ص ٨٥

حدد القانون في فئتان:

١. **المستشارون المعينون على ملاك المجلس:** قرر القانون ألا يقل عددهم عن ١٢ يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة، من الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، ومن يتمتعون بممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن ٢٢ سنة في المحاماة أو في وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتكون مدة الممارسة ٢٠ سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و ١٨ سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل أم بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على إحدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا القانون. ويجوز ترقية المستشار المساعد إلى درجة مستشار عند توافر نفس الشروط السابقة، على أن يقضي ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءته ومقدرته على العمل ونتاجيته العالية ونشر بحثين قانونيين قيمين على الأقل، وذلك بناءً على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
٢. **المستشارون المندوبون:** هم الفئة التي ينتدبها مجلس شورى الدولة للعمل من بين قضاة الصنف الاول، والمدراء العامين في دوائر وأجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام، والمدعين العامين، وأعضاء الهيئة التدريسية في كليات القانون وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط على ألا يتجاوز عدد المستشارين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.

رابعا: المستشارون المساعدون:

- وهم فئة واحدة يتم تعيينهم على ملاك مجلس شورى الدولة بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة على ألا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين
- يشترط في المساعد أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن ١٥ سنة
- وتصبح ١٣ سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و ١١ سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين
- وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على إحدى الشهادتين ممارسة لأغراض تطبيق قانون مجلس شورى الدولة على هذه الحالة.
- يحضر المستشارون المساعدون اجتماعات الهيئة العامة، والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش من دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يساهمون في أعمال الهيئات المتخصصة على ألا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
- منع المشرع توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد أو اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة إلا بعد استحصال إذن وزير العدل
- كما قضى المشرع بعدم جواز إحالة اعضاء مجلس شورى الدولة إلى التقاعد قبل إكمال كل منهم ٦٣ من العمر
- يتبين لنا إن عضوية مجلس شورى الدولة مقصورة على الرئيس ونائبيه والمستشارون، والمستشارون المساعدون وما عداهم فيعدون مجرد موظفين إداريين، وهذا يصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس هو ٢١ عضواً فقط.

المطلب الثاني - اقسام مجلس شورى الدولة: ص ٨٨

نص القانون على أن يتكون مجلس شورى الدولة مما يأتي:

١. الهيئة العامة
٢. هيئة الرئاسة
٣. الهيئات المتخصصة
٤. الهيئة الموسعة
٥. مجلس الانضباط العام
٦. محكمة القضاء الإداري

أولاً: الهيئة العامة:

- الهيئة العامة هي أعلى هيئة في مجلس شورى الدولة والتي تبشر اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وإبداء الرأي في الأمور القانونية والقضاء الإداري بصفتها التمييزية.
- تتكون الهيئة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين، وتنعقد برئاسة رئيس مجلس شورى الدولة أو برئاسة أقدم نائبيه في حالة غيابه.
- يحضر المستشارون المساعدون اجتماعات الهيئة العامة ويشاركون في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

ثانياً: هيئة الرئاسة: ص ٨٨

- وهي من الهيئات التي استحدثها التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة تتألف من رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
- تتولى كل ستة أشهر تقديم تقرير إلى ديوان رئاسة الجمهورية يتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص أو قصور أو غموض في التشريع القائم أو حالات إساءة استعمال السلطة.
- ولها وحدها الحق في اقتراح تشكيل محاكم للقضاء الإداري في المناطق الاستثنائية.
- كما لها رفع التوصية الخاصة بترقية المستشار المساعد إلى مستشار إذا استوفى شروط الترقية، إلى وزير العدل لإصدار المرسوم الجمهوري بذلك ويجوز رفع توصيتها إلى ديوان الرئاسة لإصدار المرسوم الجمهوري بذلك

ثالثاً: الهيئات المتخصصة: ص ٨٩

- الهيئة المتخصصة هي الوحدة الأساسية الأولى في مجلس شورى الدولة حيث توجد فيه عدة هيئات متخصصة لم يحدد القانون عددها.
- تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين المساعدين شرط أن لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين، ولكل هيئة سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
- تتولى هذه الهيئات النظر في مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.
- ويخضع ما تنجزه الهيئات المتخصصة في مجال التقنين للمراجعة من قبل الهيئة العامة.
- أما فيما يتعلق بما تنجزه هذه الهيئات في مجال الرأي والمشورة القانونية فإنه يكون خاضعاً لمصادقة رئيس مجلس شورى الدولة أو الهيئة العامة أو تحال إلى الهيئة الموسعة بحسب الأحوال التي نص عليها القانون.

رابعاً: الهيئة الموسعة: ص ٩٠

- الهيئة الموسعة هي إحدى الهيئات المستحدثة بموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، فهي هيئة مؤقتة يتم تأليفها كلما اقتضت الحاجة.
- تتألف من هئتين متخصصتين يعينها الرئيس وتنعقد برئاسته أو رئاسة أحد نائبيه، ويحضر المستشارون المساعدون اجتماعاتها ويشاركون في النقاش من دون حق التصويت
- تشكل الهيئة الموسعة عندما تحيل إحدى الهيئات المتخصصة ما تنجزه في مجال المشورة وإبداء الرأي إلى رئيس المجلس، فله أن يوافق عليه فيصبح بذلك نهائياً أو يعيده إلى الهيئة المتخصصة التي تجمع برئاسته لبحث الموضوع مجدداً
- فيصبح قرارها نهائياً إذا تم الاتفاق وإذا لم يتم يكون لرئيس المجلس إحالة الموضوع إلى الهيئة العامة أو إلى الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة أخرى يعينها رئيس المجلس وتنعقد الهئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

خامساً: مجلس الانضباط العام: ص ٩٠ - ٩١

- بصور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ فقد أعيد ربط مجلس الانضباط العام بمجلس شورى الدولة بعدما كان مستقلاً وأصبح هيئة من هيئات المجلس.

- بين هذا التعديل تكوين المجلس من رئيس مجلس شورى الدولة رئيسًا له ومن أعضائه أعضاء طبيعيين فيه، وحدد انعقاده برئاسة الرئيس وعضوين من أعضائه وأجاز للرئيس إنابة أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس لرئاسته.
- وقد أجاز القانون انتداب قضاة من الصنف الأول والثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
- وبموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة أصبح مجلس الانضباط العام هيئة من هيئات مجلس شورى الدولة ويمارس جانبًا من اختصاصاته في مجال القضاء الإداري وهو الجانب المتعلق ببعض شؤون الموظفين سواء أكانت تتعلق بانضباطهم أم بحقوق خدمتهم

سادسًا: محكمة القضاء الإداري : ص ٩٢

- يعد إنشاء محكمة القضاء الإداري أهم إنجاز أحدثه التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، حيث أصبح المجلس يباشر اختصاصًا قضائيًا فضلًا عن اختصاصاته في مجال التقنين وإبداء الرأي في الأمور القانونية.
- وبذلك تكون اختصاصات مجلس شورى الدولة قد اكتملت وأصبح حاله حال مجلس الدولة الفرنسي والمصري
- تتألف محكمة القضاء الإداري من رئيس المحكمة الذي يجب أن يكون قاضٍ من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنف القضاة أو من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.

المبحث الثاني - اختصاصات مجلس شورى الدولة: ص ٩٣

تتمثل اختصاصات مجلس شورى الدولة بتقديم الاستشارات لأجهزة الدولة في مجال التقنين وإبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية فضلًا عن اختصاص القضاء الإداري

المطلب الأول - اختصاصات مجلس شورى الدولة الاستشارية: ص ٩٤

يباشر مجلس شورى الدولة في سبيل أداء دوره الاستشاري اختصاصات في مجال التقنين وأخرى في مجال الاستشارة القانونية وكما يأتي:

- أولاً: دور المجلس في مجال التقنين
- ثانياً: دور المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية
- ثالثاً: سير العمل في أداء مجلس شورى الدولة لاختصاصاته الاستشارية

أولاً: دور المجلس في مجال التقنين:

إن صياغة مشروعات القوانين ودقتها من الأمور المهمة حيث إن عدم دقة التشريع تسهم في ضياع الغاية التي سعى إليها المشرع كما إن التنسيق والترابط مطلوب بين مختلف التشريعات من أجل الحفاظ على وحدة البناء القانوني في الدولة، لذا يعهد بمهمة الصياغة التشريعية إلى متخصصين أكفاء من القانونيين وقد نصت المادة الخامسة المعدلة على دور مجلس شورى الدولة في مجال التقنين على إنه يمارس ما يأتي:

١. إعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد أن يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.
٢. تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع على النحو الآتي:
 - تلتزم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بإرسال مشروع التشريع إلى الوزارة أو الوزارات أو الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس.
 - يرسل مشروع التشريع إلى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع أسبابه الموجبة وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الأعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه إلى ديوان الرئاسة مباشرة إلا في الأحوال التي ينسبها الديوان
 - يتولى المجلس دراسة المشروع وإعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعها مع توصيات المجلس إلى ديوان الرئاسة وإرسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس إلى الوزارة أو الجهة ذات العلاقة

٣. الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية
٤. تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك إلى ديوان الرئاسة تقريرًا متضمنًا ما اظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.

ثانيًا: دور المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية: ص ٩٥

يؤدي مجلس شورى الدولة دورًا مهمًا في إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية للجهات الإدارية التي تطلبها ولكن هذه الاستشارة لا تعدو أن تكون مجرد آراء استشارية غير ملزمة للجهة الإدارية التي طلبتها.. وقد بينت المادة السادسة من قانون مجلس شورى الدولة مهام المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية على النحو الآتي:

١. إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا
 ٢. إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الانضمام إليها.
 ٣. إبداء الرأي في المسائل المختلف عليها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة إذا احتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزمًا لها
 ٤. إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها
 ٥. توضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة
 ٦. لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس
- ملحوظة إن المادة ١٨ منعت المجلس من إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء، وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن

ثالثًا: سير العمل في أداء مجلس شورى الدولة لاختصاصاته الاستشارية: ص ٩٦

- تبدأ الإجراءات التي يتبعها المجلس بإحالة الرئيس لمشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس إلى إحدى الهيئات أو إلى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل لدراستها وإبداء الرأي فيها.
- وفي الهيئة المكلفة بإبداء الرأي يقوم عضو من أعضائها بدراسة الموضوع وإعداد تقرير عنه والاستكمال المعلومات له طلب حضور ممثل عن الجهة بدرجة مدير على الأقل
- ثم يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الأعضاء لمناقشتها واتخاذ القرار ويجوز للهيئة أن تدعو ممثل الجهة ذات الشأن للحضور بغية مناقشة المشروع
- وبعد أداء الهيئة لمهمتها يحال ما تنجزه إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالة مشروعات القوانين إلى الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون بحضور ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن عند الاقتضاء أو بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع.
- أما فيما يتعلق بالمشورة القانونية فيعد رأي الهيئة نهائيًا إذا وافق عليه الرئيس
- أما إذا كان للرئيس رأي مخالف فعليه إعادته إليها وعندئذ تعقد اجتماعًا برئاسته فإذا صدر قرارها بالاتفاق فإنه يصبح نهائيًا وإن لم يتفقا تحال القضية إلى الهيئة العامة أو الموسعة.

وتكون إحالة رئيس المجلس للقضية إلى الهيئة العامة في الأحوال الآتية: ص ٩٧

١. إذا أقرت إحدى الهيئات مبدأ جديدًا
٢. إذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد
٣. إذا أوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك
٤. إذا رأى رئيس المجلس أن القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأ جديدًا

ملحوظة

في جميع الأحوال تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللوزير أن يطلب من الهيئة العامة إعادة النظر في قرارها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، ويصبح القرار المعترض عليه نهائيًا إذا صدر بموافقة أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة.

المطلب الثاني - اختصاصات مجلس شورى الدولة القضائية: ص ٩٨

يتمثل الدور القضائي للمجلس بالاختصاصات التي يتولاها كل من: مجلس الانضباط العام، ومحكمة القضاء الإداري.

أولاً: مجلس الانضباط العام:

يختص مجلس الانضباط العام بنظر المنازعات المتعلقة ببعض شؤون الموظفين التي حددها قوانين مختلفة هي قانون مجلس شورى الدولة، وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية.

وعلى ضوء ذلك يمكن حصر هذه الاختصاصات وردّها إلى مجموعتين:

● المجموعة الأولى: اختصاصات المجلس في مجال انضباط موظفي الدولة

● المجموعة الثانية: اختصاصات المجلس في مجال حقوق الخدمة المدنية

المجموعة الأولى: اختصاصات المجلس في مجال انضباط موظفي الدولة:

- تتمثل اختصاصات مجلس الانضباط العام بالنظر في الطعون التي يرفعها الموظفون ضد العقوبات المفروضة عليهم وهي لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل.
- أوجب القانون على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلًا على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى التحقيق تحريًا مع الموظف المخالف المحال عليها. مادة ١٠ من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤
- بعد ذلك تحرر محضرًا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مسائلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف إليها.
- وللوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة عقوبات لفت النظر والإنذار وقطع الراتب من دون إحالته إلى لجنة تحقيقية.
- كما أعطت المادة ١٢ للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق، وللمشمول بأحكام هذه المادة الحق بالطعن في العقوبات أمام مجلس الانضباط العام.
- بموجب المادة ١٤ لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيًا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له.
- ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض عقوبة (انقاص الراتب، تنزيل درجة، الفصل، العزل.
- إن لمجلس الانضباط العام وهو ينظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل) أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها
- وإذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام إن في فعل الموظف المخال إلى التحقيق جرمًا نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته على المحاكم المختصة.
- ويشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط أن يتظلم الموظف من القرار لدى الجهة التي أصدرته خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة، وعلى الجهة البت بهذا التظلم خلال ٣٠ يومًا وعند عدم البت يعتبر التظلم مرفوضًا.
- كذلك يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقةً أو حكمًا وإذا لم يطعن بالقرار خلال هذه المدة يعتبر باتًا.
- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس الشورى الدولة خلال ٣٠ يومًا من تاريخ التبليغ به، حيث يكون قرارها الصادر بنتيجة الطعن باتًا وملزمًا كونها تمارس اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعون المقدمة في قرارات مجلس الانضباط العام.

المجموعة الثانية: اختصاصات المجلس في مجال حقوق الخدمة المدنية:

- بموجب المادة ٥٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل فقد تم اعطاء **مجلس الانضباط** العام اختصاص النظر في منازعات الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب **قانون الخدمة المدنية**
- تتمثل هذه المنازعات بالطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بالطعن في الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة (**بالتعيين، والترفع، ومنح العلاوات، والاستغناء عن الخدمة في فترة التجربة، والقضايا الخاصة بالرواتب.. إلخ**)
- **ولا تسمع الدعوى التي تقام بعد ٣٠ يومًا من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعارض عليه إذا كان داخل العراق، و ٦٠ يومًا إذا كان خارج العراق.**

ثانيًا: محكمة القضاء الإداري: ص ١٠٢

- أشار البند ثانيًا من المادة السابعة من قانون مجلس شوري الدولة إلى تشكيل محكمة تسمى (**محكمة القضاء الإداري**) في مجلس شوري الدولة
- كما أشار نفس القانون إلى إمكانية تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في **مراكز المناطق الاستثنائية عند الاقتضاء** ببيان يصدره وزير العدل بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شوري الدولة.
- تتألف المحكمة برئاسة **قاضٍ من الصنف الأول أو من مستشار في مجلس شوري الدولة** وعضوين من القضاة لا يقل صنفها عن الصنف الثاني أو من المستشارين المساعدين في مجلس شوري الدولة

س| ما هو اختصاص محكمة القضاء الإداري ؟

ج| تختص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام، بناءً على طعن يوجه من قبل المعني بالقرار.

س| ما هي أسباب الطعن في القرارات والأوامر؟

ج| يعد من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:

١. أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات
٢. أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيبتاً في شكله
٣. أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة.

ملحوظة

يعد في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها **رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً.**

س| ما هي إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري؟

- لم يتضمن قانون مجلس شوري الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ قواعد إجرائية خاصة بالمنازعات الإدارية، وقد اكتفى المشرع ببعض النصوص لبيان الإجراءات قبل وأثناء نظر المنازعة الإدارية، وجعل من **قانون المرافعات المدنية المكمّل** لما لم يرد به نص في القانون المذكورة.
- وقد أوجب القانون التظلم أمام الجهة الإدارية أولاً قبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري **حسب نص المادة السابعة فقرة ثانياً** والتي نصت على "يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن أمام الجهة الإدارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تسجيل التظلم لديها"
- إن تقديم التظلم لم تحدد له مدة من قبل المشرع بعد صدور القرار الإداري حيث يمكن لصاحب العلاقة تقديم تظلمه متى شاء، وهذا يعد نقضاً في **التشريع مقارنةً ببقية الدول.**
- وعلى الإدارة أن تبت بالتظلم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
- كما أوجبت الفقرة (ز) من المادة السابعة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ انتهاء مدة الـ ٣٠ يومًا المنصوص عليها في الفقرة (و) من نفس المادة **والا سقط حقه في الطعن.**

- إن مضي مدة الستون يوماً تعني تحصن القرار الإداري من الطعن به حتى لو كان القرار غير مشروع.
- ولكن عند فوات هذه المدة، أجاز القانون لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء العادي لإقامة دعوى التعويض حسبما جاء في المادة (٧/ ثانياً/ ط) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الشورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩

س| ما هي صلاحية المحكمة الإدارية ؟ ص ١٠٥

للمحكمة أن تقرر عند نظر الدعوى ما يلي:

١. رد الطعن: يجوز لها رد الطعن إذا كان الطعن لم يستوف الشروط الواجب توافرها في إقامة الدعوى، كمرور مدة الطعن في القرار الإداري
٢. إلغاء القرار: يجوز لها إلغاء القرار إن كان معاب بأحد عيوب المشروعية كغيب الشكل .. إلخ، وقد يكون قرار الإلغاء كاملاً أو جزئياً ومن نتائج الإلغاء يكون أثره عام ويزيل القرار بأثر رجعي
٣. تعديل القرار: للمحكمة الحق في تعديل القرار وذلك بإلغاء جزء منه، كحالة عدم التناسب بين السبب ومحل القرار وهذا يعني رقابة عنصر الملائمة في القرار الإداري.
٤. الحكم بالتعويض: منح المشرع للمحكمة صلاحية الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي شريطة أن يثبت الضرر الذي أصابه جراء القرار غير المشروع.

س| ما هي القيود التي ترد على اختصاص المحكمة الإدارية ؟ ص ١٠٥ - ١٠٦

حسب نص المادة السابع من قانون مجلس شورى الدولة والتي منعت محكمة القضاء الإداري من النظر في عدد من القرارات وهي:

١. أعمال السيادة: كالقرارات والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية
٢. القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.
٣. القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها. تنبيه هذه الاستثناءات مخالفة لنص المادة ١٠٠ من الدستور

س| كيف يتم تمييز حكم الإلغاء الصادر من محكمة القضاء الإداري ؟ ص ١٠٦

ج| بعد صدور الحكم يكون قابلاً للطعن به لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال مدة ٣٠ يوماً من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الاتحادية باتاً وملزماً.

س| ما هي أسباب الطعن تمييزاً لدى المحكمة الاتحادية العليا ؟ ص ١٠٧

ج| إن أسباب التمييز محددة على سبيل الحصر وهي:

١. إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.
٢. إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
٣. إذا وقع في الإجراءات المتبعة عند رؤية الدعوى خطأ مؤثراً في صحة الحكم.
٤. إذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات.

س| ما هي إجراءات الطعن بأحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ ص ١٠٧

ج| يقدم الطعن بواسطة رئيس محكمة القضاء الإداري الذي يقوم بالتأشير عليه واستيفاء الرسم القانوني عنه، ويرفعه مع إضارة الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا وتسجل الدعوى حسب أسبقية ورودها وينظر في الطعن وفقاً للقانون.

س| ما الحكم الذي تصدره المحكمة الاتحادية العليا في الطعن التمييزي ؟ ص ١٠٨

بعد تقديم الطعن تنظر المحكمة الاتحادية العليا حيث تقوم بإجراء التدقيقات لأوراق الدعوى دون أن تجمع الطرفين ولها ذلك عند الاقتضاء.

وبعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة قرارها على أحد الوجوه الآتية:

١. رد العريض التمييزية إذا كانت العريضة مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو إذا وجدت إنها خالية من الأسباب التي بني عليها الطعن.
٢. تصديق الحكم المميز إذا كان موافقاً للقانون.
٣. نقض الحكم المميز إذا توافر سبب من الأسباب الآتية:

- أ- إذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.
- ب- إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
- ت- إذا وقع في الإجراءات خطأ مؤثر في صحة الحكم.
- ث- إذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها.
- ج- إذا وقع في الحكم خطأ جوهري في فهم الوقائع.

المبحث الثالث - القضاء الإداري في إقليم كردستان - العراق

المطلب الأول - تنظيم المجلس: ص ١١٠

حدد قانون مجلس الشورى لإقليم كردستان رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٨ كيفية تنظيم مجلس شورى الإقليم، ومن أجل بيان تنظيمه فإن ذلك يقتضي استعراض عنصرين رئيسيين هما الأعضاء وتكوين المجلس.

الفرع الأول :- أعضاء المجلس:

حددت المادة الثانية من القانون أعضاء مجلس الشورى لإقليم كردستان حيث ينبت إنه يتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على تسعة.

أولاً: رئيس مجلس شورى الإقليم:

- يعين بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس الوزراء يتولى رئيس المجلس رئاسة الهيئة العامة وهيئة الرئاسة.
- وقد منحه القانون حق اختيار ثلاثة من بين أعضاء المجلس كـ أعضاء في الهيئة المختصة بنظر التنازع في الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة المدنية.

ثانياً: نائب رئيس مجلس الشورى: ص ١١١

- لرئيس المجلس نائب يتم تعيينه بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- يتولى رئاسة الهيئة العامة عند غياب الرئيس كما يتولى رئاسة هيئة انضباط موظفي الإقليم.

ثالثاً: المستشارون:

وهم فئتان:

١. المستشارون على الملأ: حدد القانون عددهم بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسع، يتم تعيينهم بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية لمدة لا تقل عن ٢٠ سنة في الوظيفة القضائية أو المحاماة وتكون مدة الممارسة ١٨ سنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير و ٢٠ سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه وتعد مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من هاتين الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون.
٢. المستشارون المنتدبون: يتم انتدابهم للعمل في مجلس الشورى من بين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد وموافقتهم التحريرية ومن قضاة الصنف الأول وموافقتهم التحريرية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رابعاً: المستشارون المساعدون: ص ١١٢

- يتم تعيينهم على ملاك مجلس الشورى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وتوصية من هيئة رئاسة مجلس الشورى.
- وتشترط المادة ٢٣ من القانون أن يكون المستشار المساعد حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية لمدة لا تقل عن ١٥ سنة تصبح ثلاث عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير و ١٠ سنوات بالنسبة للحاصل شهادة الدكتوراه
- وتعد مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من هاتين الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون.
- ويحضر المستشارون المساعدون اجتماعات الهيئة العامة ويشتركون في النقاش من دون أن يكون لهم حق التصويت.

- من الضمانات التي أقرها المشرع لأعضاء المجلس، منع توقيف الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المنتدب أو المستشار المساعد أو اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقهم إلا بإذن وزير العدل باستثناء ارتكابهم جنائية مشهودة.
- كما قضى بإحالة الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المساعد على التقاعد عند إكمالهم سن الـ ٦٥ من العمر ويطبق بحقهم قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا.
- مما تقدم يتضح لنا بأن الحد الأدنى لأعضاء المجلس هو ٦ أعضاء.

الفرع الثاني :- تكوين المجلس: ص ١١٣

نص القانون على إن مجلس شورى الإقليم يتكون من:

١. الهيئة العامة.
٢. هيئة الرئاسة.
٣. هيئة انضباط موظفي الإقليم.
٤. محكمة القضاء الإداري.

أولاً: الهيئة العامة:

- تقع الهيئة العامة على رأس تشكيلات مجلس شورى الإقليم فهي أعلى هيئة فيه وتباشر اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وإبداء الرأي والمشورة القانونية والقضاء الإداري.
- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبه والمستشارين والمستشارين المساعدين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة نائبه ويتم النصاب القانوني بحضور ثلاثة أرباع أعضائها.
- ويجوز المستشارون المساعدون اجتماعات الهيئة العامة من دون أن يكون لهم حق التصويت

ثانياً: هيئة الرئاسة:

تتألف من الرئيس ونائبه واقدام المستشارين وتقوم هيئة الرئاسة بإحالة مشروعات القوانين والقضايا على الهيئة العامة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.

ثالثاً: هيئة انضباط موظفي الإقليم:

تتألف من نائب الرئيس وعضوية اثنين من المستشارين تسميهم هيئة الرئاسة وعند غياب نائب الرئيس يرأس الهيئة المستشار الأقدم.

رابعاً: محكمة القضاء الإداري:

هي إحدى تشكيلات مجلس الشورى لإقليم كردستان - العراق وإنشائها تكون اختصاصات مجلس الشورى قد تكاملت، حيث أصبح يباشر اختصاصاً قضائياً إلى جانب اختصاصاته في مجال التقنين وإبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية.

المطلب الثاني - اختصاصات مجلس شورى الإقليم

الفرع الأول - اختصاصات المجلس الاستشارية: ص ١١٥

يباشر مجلس شورى الإقليم نوعين من الاختصاصات في المجال الاستشاري

وهما

١. التقنين.
٢. إبداء الرأي والمشورة القانونية.

أولاً: دور المجلس في مجال التقنين: ص ١١٥

وفق المادة السابعة، يمارس المجلس في سبيل أداء هذه المهمة ما يأتي

١. إعداد وصياغة مشروعات القوانين في الإقليم بطلب من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
٢. تدقيق مشروعات القوانين المعدة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع.
٣. ترسل مشروعات القوانين إلى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان أسبابه الموجبة وجميع الأعمال التحضيرية.

٤. استطلاع رأي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بمشروعات القوانين الواردة إليه، وله طلب حضور ممثل عنها لا تقل درجته عن مدير عام للغرض المذكور.

٥. يقوم المجلس بدراسة المشروع وإعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ورفعها مع توصيات المجلس إلى مجلس الوزراء وإرسال نسخة من المشروع والتوصيات إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً: دور المجلس في مجال إبداء الرأي والمشورة القانونية: ص ١١٦

بموجب المادة ٨٠ يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية ما يأتي

١. إبداء الرأي في المسائل المختلف عليها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة، إذا احتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأيه ملزماً لها.

٢. توضيح الأحكام القانونية بناءً على طلب إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.

تنبيه

أشارت المادة ١٠ إلى أنه لا يجوز لغير الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.

كما حظر على المجلس إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء أو التي لها مرجع قانوني للطعن.

وتمتضى المادة ١١ لوزير العدل أن يحيل على المجلس القضايا التي يتأى حالتها عليه لدراستها وإبداء الرأي فيها أو إعداد مشروعات القوانين التي ترى تشريعها.

الفرع الثاني - اختصاصات المجلس القضائية: ص ١١٧

تمثل الدور القضائي لمجلس شوري الإقليم بالاختصاصات التي تتولاها كل من:

١. هيئة انضباط موظفي الإقليم.

٢. محكمة القضاء الإداري.

أولاً: هيئة انضباط موظفي الإقليم:

تختص هيئة انضباط موظفي الإقليم بالنظر في المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين التي حددها قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة

ويمكن حصر هذه الاختصاصات في مجموعتين:

المجموعة الأولى:- اختصاص الهيئة في مجال حقوق الخدمة المدنية:

• بموجب المادة ٢٠ أولاً من القانون، فإن هيئة انضباط موظفي الإقليم تنظر بالطعون التي يقدمها أصحاب الشأن في الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات.. إلخ

• ولا تسمع الدعاوى التي تقام بعد ٣٠ يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعارض عليه إذا كان داخل العراق ٦٠ يوماً إذا كان خارجاً.

• ويكون قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم بشأن الدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة قابلاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال ١٥ يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويكون قرارها الصادر بنتيجة الطعن باتاً.

المجموعة الثانية:- اختصاص الهيئة في مجال انضباط موظفي الإقليم:

• حدد قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل في المادة الثامنة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف وهي (لفت النظر، والانتذار، وقطع الراتب، والتوبيخ، وانقاص الراتب، وتنزيل الدرجة، والفصل، والعزل)

• وبموجب المادة ٢١ من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٨ فإن للموظف المعاقب بإحدى هذه العقوبات أن يعترض أمام هيئة انضباط موظفي الإقليم، ويكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.

ثانياً: محكمة القضاء الإداري: ص ١١٨

أشارت المادة ١٢ من القانون، بأن لوزير العدل تشكيل المحاكم الإدارية في مركز المحافظات بحسب مقتضيات المصلحة العامة.

وتشكل المحكمة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاضٍ ومستشار ولوزير العدل انتداب قضاة إلى

محكمة القضاء الإداري من غير المنتدبين إلى مجلس شوري الإقليم من رئاسة مجلس القضاء.

س| ما هو اختصاص المحكمة الإدارية الإقليمية؟ ص ١١٨

بموجب المادة ١٣ من القانون تختص محكمة القضاء الإداري بما يأتي:

١. النظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة من الموظفين والهيئات في دوائر الإقليم، والتي لم يعين مرجعاً للطعن فيها.
٢. الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات المحلية.
٣. الفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات أو الافراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
٤. دعاوى الجنسية .
٥. طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة من القرار الإداري الصادر خلافاً للقانون.
٦. الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في قضايا الضرائب والرسوم، وفق القانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.
٧. الطعن في رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في الدوائر وأجهزة الإقليم عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً.

س| ما هي إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري الإقليمية؟ ص ١١٩

- اشترطت المادة ١٧ من القانون، قبل تقديم الطعن إلى المحكمة أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت فيه خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
- كما أعطت للمتظلم عند رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المنصوص عليها وهي ١٥ يوماً أن يطعن لدى محكمة القضاء الإداري خلال مدة ٣٠ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم، وإلا سقط حقه في الطعن.

س| ما هي صلاحية المحكمة الإدارية الإقليمية؟

ج| تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها ولها أن تقرر ما يلي:

رد الطعن أو إلغائه، تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناءً على طلب الطاعن.

س| ما هي القيود التي ترد على اختصاص المحكمة الإدارية الإقليمية؟

ج| بموجب المادة ١٦ من القانون، فإن محكمة القضاء الإداري لا يجوز لها النظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة وتنقسم إلى قسمين أولها صلاحيات رئيس الإقليم في الظروف العادية وثانيها صلاحيات رئيس الإقليم في الظروف الاستثنائية أو في حالة الضرورة.

ملحوظة

إن الاستثناءات الواردة على اختصاصات محكمة القضاء الإداري تعد خرقاً لنص المادة ١٠٠ من دستور جمهورية العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

س| كيف يتم تمييز القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري الإقليمي؟ ص ١٢١

- بموجب المادة ١٨ من القانون يكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم خلال مدة ٣٠ يوماً من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الصادر بنتيجة الطعن بائناً.
- وتبعاً لما قرره المادة ١٩ من القانون من وجوب إتباع الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم اختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر بالطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري.

الباب الرابع - دعوى الإلغاء: ص ١٢٣

دعوى الإلغاء:- هي دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالباً فيها إلغاء قرار إداري صدر مخالفاً للقواعد القانونية النافذة.

- إن دعوى الإلغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وتعد الوسيلة الأساسية للتصدي للقرار الإداري غير المشروع بسبب وجود عيب أو أكثر في ركن من أركانه.
- أما دعوى الإلغاء في العراق فهي من خلق المشرع الذي نظم أحكامها في قانون مجلس شورى الدولة بنصوص صريحة وواضحة.

س| ما هي خصائص دعوى الإلغاء؟ ص ١٢٤

١. من صنع القاضي الإداري.
٢. دعوى قضائية.
٣. دعوى موضوعية.

٤. دعوى عامة للشرعية.

أولاً: دعوى الإلغاء من صنع القاضي الإداري:

- في فرنسا نشأت هذه الدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنسي، أما وضعها في العراق يختلف عنه في فرنسا، حيث نشأت الدعوى بمقتضى نصوص تشريعية إلا إن محكمة القضاء الإداري قد لعبت دوراً رئيسياً وانشأتها وذلك بابتداعها الحلول المناسبة لأمر لم ترد في النصوص التشريعية.

ثانياً: دعوى الإلغاء دعوى قضائية:

الدعوى القضائية: هي تلك التي يصدر فيها القضاء حكماً واجب التنفيذ من دون توقف على تصديق جهة أخرى.

- إن دعوى الإلغاء في فرنسا نشأت كتوصية تصدر من جانب مجلس الدولة الفرنسي يحتاج تنفيذها إلى صدور قرار بالتنفيذ من جانب رئيس الدولة أو الوزير أو المحافظ المختص.
- إلا إن الأمر تغير فانتقلت دعوى الإلغاء بذلك من مرحلة القضاء المحجوز إلى مرحلة القضاء المفوض فأصبح مجلس الدولة يصدر أحكاماً قضائية لا مجرد توصيات إدارية.

ثالثاً: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية: ص ١٢٥

- تعد دعوى الإلغاء من القضاء الموضوعي، لأنها تتعلق بفحص شرعية القرار المطعون فيه، كما إن الحكم الذي يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً.
- فهي تكون ضد القرار الإداري ذاته وليست ضد شخص معين، إذ إن محل الدعوى هو القرار الإداري المطعون فيه وليس الشخص مصدر القرار، فهدف دعوى الإلغاء هو حماية القواعد القانونية وضمان عدم مخالفتها.

رابعاً: دعوى الإلغاء دعوى عامة للشرعية:

- دعوى الإلغاء هي طريق الطعن الأصلي لإلغاء القرارات الإدارية، فهي دعوى عامة بمعنى إنها الدعوى التي يتم اللجوء إليها لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة.
- فهدفها هو حماية الشرعية وتقرير سيادة القانون، وذلك بإلغاء أي قرار يخالف الشرعية ويعد خروجاً عليها.
- بهذا المفهوم تعد دعوى الإلغاء من النظام العام فهي دعوى يجوز تحريكها ضد أي قرار إداري غير مشروع، فلا يجوز منع رفعها إلا بنص خاص.

س | تمييز دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض؟ ص ١٢٦

تتميز دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض من أوجه عديدة هي:

١. من حيث موضوع النزاع.
٢. من حيث الاختصاص.
٣. من حيث المواعيد.
٤. من حيث سلطة القاضي.
٥. من حيث حجية الحكم.

أولاً: من حيث موضوع النزاع:

- يكون موضوع النزاع في دعوى التعويض هو حق شخصي يطالب به المدعي
- بينما يكون موضوع النزاع في دعوى الإلغاء حق عيني حيث يطالب المدعي بإلغاء قرار إداري غير مشروع.

ثانياً: من حيث الاختصاص:

- تختص محاكم القضاء الإداري وحدها بإلغاء القرارات الإدارية
- الأصل في التعويض يكون من اختصاص القضاء الإداري، إلا إنه في حالات يكون الاختصاص بالتعويض فيها للمحكمة العادية.

ثالثًا: من حيث المواعيد:

- ميعاد دعوى الإلغاء ٦٠ يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- بينما يتحدد ميعاد دعوى التعويض بميعاد تقادم الحق المطالب به أو سقوطه كما توجد بعض أوجه الاختلاف في الإجراءات بين الدعويين.

رابعًا: من حيث سلطة القاضي:

- تنحصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص مشروعية القرار الإداري فإذا وجده غير مشروع يحكم فقط بإلغائه.
- أما في دعوى التعويض فإن القاضي يتمتع بسلطات أكبر حيث تكون له سلطة تحديد المركز القانوني للمدعي وتحديد قيمة التعويض المستحق له مما أدى إلى تسمية هذا القضاء باسم القضاء الكامل.

خامسًا: من حيث حجية الحكم:

- حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض حجية نسبية أي أن أثر الحكم يكون في مواجهة أطراف الدعوى فقط.
- أما الحكم في دعوى الإلغاء فتكون حجته عامة حيث أن له حجية على كافة أطراف الدعوى وعلى الغير لأن القضاء هنا عينيًا.

الفصل الأول - شروط قبول دعوى الإلغاء: ص ١٢٨

شروط قبول دعوى الإلغاء:- هي الشروط التي يجب توافرها في الدعوى لكي يمكن قبولها أمام المحكمة المختصة.

- إذ يترتب على وجودها مباشرة المحكمة في فحص موضوع المنازعة.
- أما في حال تخلف أحد هذه الشروط تقرر المحكمة رد الدعوى دون أن تتعرض لمبحث موضوعها.

المبحث الأول - شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه بالإلغاء: ص ١٢٩

يشترط أن تتوفر في القرار المطعون فيه بالإلغاء ثلاثة شروط أساسية

وهي:

١. أن يكون القرار المطعون فيه نهائيًا.
٢. أن يكون القرار الإداري مؤثرًا في مركز الطاعن.
٣. أن يكون القرار الإداري صادرًا من سلطة إدارية وطنية.

أولًا: أن يكون القرار المطعون فيه نهائيًا:

- أن يكون نهائيًا، أي أن يكون قد صدر من جهة إدارية من دون الحاجة إلى التصديق عليه من جهة أعلى.
- فإذا كان القرار غير قابل للتنفيذ لضرورة التصديق عليه من الرئيس الإداري فإنه لا يكون نهائيًا ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.

ثانيًا: أن يكون القرار الإداري مؤثرًا في مركز الطاعن: ص ١٣٠

- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يحقق القرار الإداري المطعون فيه ضررًا لرافع الدعوى.
- أي أن يكون من شأن القرار أن يولد آثارًا قانونية تؤثر في مركز الطاعن كصدور قرار إداري بتنحية مدير عام عن منصبه.

ثالثًا: أن يكون القرار الإداري صادرًا من سلطة إدارية وطنية: ص ١٣١

القاعدة العامة أن دعوى الإلغاء تقبل الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية الوطنية، ولا تقبل الطعن ضد القرارات الصادرة من سلطات إدارية أجنبية.

- كما يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون صادرًا من سلطة إدارية، سواء كانت مركزية كرئيس مجلس الوزراء أو لا مركزية كالمجالس البلدية.

المبحث الثاني - شرط يتعلق بمصلحة رفع الدعوى: ص ١٣٣

يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود مصلحة لرافع الدعوى، إذ لا دعوى من دون مصلحة، فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها.

وينبغي لتوضيح هذا الشرط بيان شروط وأنواع المصلحة في دعوى الإلغاء:

• أولاً: شروط المصلحة في دعوى الإلغاء.

• ثانياً: أنواع المصالح في دعوى الإلغاء.

أولاً: شروط المصلحة في دعوى الإلغاء: ص ١٣٣

يشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر شرطين أساسيين هما:

١. أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: يجب أن يكون القرار المطعون فيه قد أثر تأثيراً مباشراً في المركز القانوني للطاعن، سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم معنوية وسواء كانت محققة أم محتملة.

أ- المصلحة المادية والمصلحة الأدبية: تعد المصلحة المادية للطاعن متوافرة في حالة طلب إلغاء قرار إداري برفض منحة الترخيص لمزاولة مهنة معينة، وقد تكون المصلحة أدبية كما في حالة الطعن بإلغاء القرار الصادر بسحب الجنسية، كما قد تكون مصلحة الطاعن مادية وأدبية في آن واحد كما في حالة طعن الموظف في قرار فصله من الوظيفة.

ب- المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة: تكون المصلحة محققة إذا تأكد مقدماً إن المدعي سينال فائدة من إلغاء القرار المطعون فيه، وتكون المصلحة محتملة إذا كان ليس من المؤكد حصول هذه الفائدة عاجلاً لرفع الدعوى.

٢. توافر المصلحة وقت رفع الدعوى: إن توافر المصلحة عند رفع الدعوى يعد شرطاً لقبولها، أما عن ضرورة استمرار تحقق هذا الشرط لحين الفصل في الدعوى فإنه محل خلاف، لذا سنكتفي بما أخذ به القضاء الإداري في العراق حيث اشترط بقاء المصلحة قائمة بعد رفع الدعوى وعدم زوالها حتى الفصل فيها.

ثانياً: أنواع المصالح في دعوى الإلغاء: ص ١٣٥

تنقسم دعوى الإلغاء عادةً على أساس صفة الطاعن، فالمستدعي في دعوى الإلغاء قد يكون من الأشخاص الطبيعيين سواء كان فرداً عادياً أو موظفاً عاماً كما قد يكون هيئة من الهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية.

١. مصالح الأفراد.

٢. مصالح الموظفين.

٣. مصالح الهيئات.

أولاً: مصالح الأفراد:

تتعدد صفات الأفراد غير الموظفين، ومن ثم تتحدد مصالحهم وتختلف من مركز قانوني إلى آخر

وذلك على النحو الآتي: ص ١٣٦

١. مصلحة المالك: للمالك بصفته مالكا أن يطعن بالإلغاء في أي قرار إداري معيب يمس مصالحه المشروعة، حتى لو لم يصل هذا المساس إلى مستوى الاعتداء على الحق.

٢. مصلحة المستفيد من خدمات المرفق العام: مثال ذلك أن يطعن المستفيد من خدمات مرفق اقتصادي ضد القرارات الصادرة بتنظيم العمل بالمرفق إذا ترتب عليها ضرراً للمستفيدين من خدمات المرفق.

٣. مصلحة صاحب المهنة: يكون لكل صاحب مهنة أن يطعن في القرارات التي تنظم مهنته أو حرفته، خصوصاً إذا تضمنت هذه القرارات مساساً بحرية الصناعة والتجارة.

٤. مصلحة الممول: وهو الشخص دافع الضريبة، إذ له أن يطعن بالإلغاء في أي قرار إداري مخالف للقانون يترتب عليه اتفاق الأموال، وتكون له مصلحة في رفع دعوى الإلغاء بصفته من دافعي الضرائب.

٥. مصلحة الناخب: يجوز له أن يطعن في القرارات الإدارية الخاصة بانتخاب الهيئات أو المجالس البلدية، وذلك بصفته ناخب حيث يتوافر بالنسبة له شرط المصلحة.

٦. مصلحة الساكن: يقبل من الساكن الطعن بالإلغاء ضد القرارات المتعلقة بالسكن في المدينة.

٧. مصلحة المنتمي لأحد الأديان: لأبناء الطائفة الدينية حق الطعن بالقرارات التي تمس عقيدتهم أو ممارستهم لشعائهم الدينية.

ثانياً: مصالح الموظفين: ص ١٣٧

- وهي الطعون التي يتقدم بها الموظف العام ضد القرارات التي تمس مصالحه فيما يتعلق بشؤون الوظيفة.
- حيث يتواجد الموظف بالنسبة لهذه القرارات في مركز قانوني يجعل له مصلحة شخصية في طلب إلغائها إذا كانت تلك القرارات معيبة.
- أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بتنظيم المرفق العام فلا مصلحة للموظف بالطعن فيها لأن تنظيم المرفق العام إنما يهدف لتحقيق المصلحة العامة ومن واجب الموظف القيام بواجباته الوظيفية طبقاً للقوانين المنظمة لعمل المرفق.

ثالثاً: مصالح الهيئات: ص ١٣٨

- للهيئات ذات الشخصية المعنوية كالتقابات والجمعيات طلب إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة التي قد تلحق ضرراً بالأهداف التي وجدت من أجلها.
- أما بالنسبة للقرارات التي تتصرف آثارها على عضو معين فإن له حق الطعن فيها وللهيئة التي ينتهي إليها التدخل بعد رفع الدعوى، كما يجوز لهذه الهيئة أن ترفع دعوى باسم الموظف وبناءً على توكيل منه.

المبحث الثالث - شرط ميعة رفع دعوى الإلغاء: ص ١٣٩

- لعدم ترك المنازعات بين الإدارة والأفراد إلى ما لا نهاية فقد حدد المشرع ميعة للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية.
- إذ أوجب المشرع على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة ٦٠ يوماً من تاريخ انتهاء مدة الـ ٣٠ يوماً المحددة للإدارة للرد على التظلم، في حال سكوتها عن الرد أو رفضها للتظلم
- وذلك طبقاً للمادة ٧٠ ثانياً من قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩
- وإن مدة الطعن تعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- المطلب الأول - بدء ميعة الطعن: ص ١٤١
- يبدأ ميعة الطعن بالإلغاء من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه.

أولاً: النشر:

- النشر: هو الإجراء الذي يعتد به لبدء سريان ميعة رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية التنظيمية.
- فهي تخاطب عدد غير محدود من الأفراد وتحمل قواعد موضوعية تنصف بالتجريد والعموم.
- كما إن النشر الذي يعتد به بالنسبة لهذه القرارات هو الذي يجري في الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية وليس في أي وسيلة أخرى كالصحف المحلية أو وسائل الإعلام.
- ولكي ينتج النشر أثره بالنسبة لسريان ميعة رفع دعوى الإلغاء فإنه يجب أن يكشف عن محتوى القرار ومضمونه ويعد النشر قرينة لا تقبل إثبات العكس على علم أصحاب الشأن بالقرار الإداري.

ثانياً: التبليغ: ص ١٤٢

- التبليغ: هو الطريقة التي تنقل بها الإدارة مضمون القرار إلى علم فرد أو أكثر معينين بذواتهم.
- كقاعدة عامة، التبليغ هو الوسيلة الأساس للعلم بالنسبة للقرارات الفردية، إلا إن مجلس الدولة الفرنسي قد خرج على هذه القاعدة العامة عندما قضى بوجوب نشر القرارات الفردية التي تتعلق بعدد كبير من الأفراد ويتعذر تبليغهم.
- كما يشترط في التبليغ أن يكون شاملاً لعناصر القرار الإداري حتى ينجح أثره في سريان ميعة الطعن بالإلغاء.
- وأن يوجه التبليغ إلى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه، أما إذا كان الشخص معنوي كالشركات فيوجه التبليغ إلى ممثل الشخص المعنوي أو من ينوب عنه قانوناً.
- كقاعدة عامة الإدارة غير ملزمة باتباع وسيلة معينة في تبليغ ذوي الشأن، فقد يكون عن طريق البريد برسالة أو بواسطة محضر.. إلخ كما إن التبليغ قد يكون كتابةً وقد يكون شفاهاً.

ثالثًا: العلم اليقيني: ص ١٤٣

العلم اليقيني:- هو علم صاحب المصلحة بفحوى القرار علمًا يقينيًا نافيًا للجهالة.

- وقد أخذ القضاء الإداري في العراق مبدأ العلم اليقيني حيث اعتمد في قضائه على العلم اليقيني كدليل على العلم بالقرار وإن عبء إثباته يقع على عاتق الإدارة.

المطلب الثاني - حالات إطالة المدة: ص ١٤٤

إن ميعاد الطعن قد يمتد لأسباب قانونية أو قضائية محددة مما يؤدي الى إطالة المدة بوقف هذا الميعاد أو قطعه علمًا إن الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء من النظام العام

أولًا: وقف الميعاد:

وقف ميعاد الطعن: هو عدم سريان مدته بعد بدئها بصفة مؤقتة على أن يستكمل سريانه بعد زوال سبب الوقف.

- يترتب على وقف ميعاد الطعن احتساب ما انقضى من ميعاد الطعن ويسري ما بقي من المدة استكمالًا لها.
- وبقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء بسبب القوة القاهرة كالحرب والوباء.. إلخ.
- مثاله كأن تمضي على مدة الطعن ٤٠ يومًا ثم تحصل حالة القوة القاهرة فيتوقف الميعاد عند حد ٤٠ يوم وبعد زوال الحادث يبدأ سريان الميعاد لاستكمال مدة ٦٠ يوم، وذلك عند مضي المدة المتبقية وهي ٢٠ يوم.

ثانيًا: قطع الميعاد: ص ١٤٥

قطع الميعاد:- هو أن يقع أمر معين أو حادثة محددة تؤدي إلى إسقاط الأيام التي مضت من حساب الميعاد.

- إذ تلغى المدة السابقة ويبدأ احتساب مدة جديدة بعد انتهاء الأمر الذي نتج عنه قطع المدة.

وينقطع ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء بأجراء من ثلاث إجراءات، هي:

١. التظلم الإداري.
٢. طلب الإعفاء من الرسوم القضائية.
٣. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

أولًا: التظلم الإداري:

التظلم الإداري:- هو طلب يتقدم به صاحب المصلحة الى الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار طالبًا منها إعادة النظر في قرارها الذي أضر به أو مس مركزه القانوني وذلك بسحبه أو إلغائه أو تعديله.

وينقسم التظلم إلى نوعين:

١. التظلم الاختياري: هو إعطاء الحق لأصحاب العلاقة بالتوجه إلى الإدارة للتظلم من قرارها أو اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن بالقرار الإداري. وهذا يعني إن للشخص إقامة الدعوى القضائية من دون انتظار نتيجة البت في تظلمه من قبل الإدارة.

٢. التظلم الوجوبي (الإجباري): وهو حالة فرض المشرع على صاحب المصلحة وجوب التظلم من القرار الإداري أمام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به أمام القضاء وبذلك يصبح شرطًا لقبول دعوى الإلغاء. وقد نصت الفقرة ثانيًا من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ على أن جميع التظلمات هي وجوبية من أجل رفع دعوى الإلغاء.

س| ما هي شروط التظلم ؟ ص ١٤٧

١. أن يقدم التظلم من قبل صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا.
٢. أن يقدم التظلم بعد صدور القرار الإداري.
٣. رفع التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها، ويعد الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته.
٤. أن يقدم التظلم في الميعاد الذي حدده القانون، أو خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى الإلغاء.
٥. يجب أن يكون التظلم واضحًا ومحدد المعنى، أي أن تكون عباراته دقيقة وغير مبهمة مع ذكر الجهة التي صدر عنها القرار واسم الطاعن.

٦. أن يكون التظلم مجديًا، فإذا أعلنت الإدارة سلفًا إنها لن تنظر في التظلمات المقدمة بشأن القرار يعد تظلمًا غير مجديًا.

س| ما هي أهمية التظلم وما الحكمة منه ؟ ص ١٤٨

١. يجبر الإدارة على سلك سبيل التأني عند إصدارها لقراراتها، لأنها تخشى من إعادة النظر فيها من قبل الجهات الإدارية العليا.
٢. يخفف التظلم عن كاهل القضاء، حيث إنه يقلل الوارد من القضايا بقدر المستطاع.
٣. يبسط المشروعية على أكبر قدر ممكن من أعمال الإدارة.
٤. يمثل رقابة متكاملة، لأن التظلم لا يقتصر على فحص مشروعية العمل وإنما يمتد ليشمل ملائمة العمل الإداري.
٥. يشكل رقابة فعالة وسريعة مقارنة بالرقابة القضائية حيث لا يتطلب النظر فيها إلى تحضير أوراق ومستندات كذلك التي تتطلبها الرقابة القضائية.
٦. إن كثرة التظلمات الإدارية من موضوع معين تتخذ الإدارة بصدده حلول يمكن أن يقدم للسلطة التشريعية دراسات ووثائق معتبرة تكون لها دليلاً عند إصدارها لقانون جديد.

س| ما هي آثار التظلم ؟ ص ١٤٩

- إن التظلم المعتبر قانونًا لقطع ميعة دعوى الإلغاء، هو الذي يقع قبل انقضاء مدة الطعن القضائي، وبتقديم التظلم إلى الإدارة ينقطع ميعة الدعوى.
- وعلى الإدارة البت في التظلم خلال مدة ٣٠ يوم من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت في التظلم أو رفضه، تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها.

ثانياً: طلب الإخفاء من الرسوم القضائية: ص ١٥٠

- استقر القضاء على اعتبار تقديم طلب الإخفاء من الرسوم القضائية، قاطعاً لسريان ميعة رفع دعوى الإلغاء لتبدأ مدة ٦٠ يوم جديدة.
- لذا فإن حساب المدة يبدأ من تاريخ إعلان قرار المحكمة بقبول طلب الإخفاء أو برفضه.
- فإذا جاء القرار بقبول طلب الإخفاء يقيم دعواه خلال الميعاد الجديد وهو ٦٠ يوماً وإذا جاء بالرفض يرفع دعواه بعد سداد هذه الرسوم.

ثالثاً: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة:

- يؤدي رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة إلى قطع مدة الطعن المقررة لرفع الدعوى.
- ويبقى ميعة الطعن منقطعاً حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وعندها يبدأ سريان الميعاد الجديد وهو ٦٠ يوماً من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص.

المطلب الثالث - آثار انتهاء مدة الطعن بالإلغاء: ص ١٥٢

- إن فوات الميعاد المقرر لرفع الدعوى من النظام العام، لذا لا يجوز للمحكمة أن تتجاهله، والأثر الذي يترتب على انقضاء ميعة الطعن بالإلغاء تجاه قرار إداري من دون رفع الدعوى يصبح القرار نهائياً ومحصناً تجاه أي طعن بعدم المشروعية.
- لكن القضاء الإداري وضع بعض الحلول بغية تطهير الساحة القانونية من أي قرار إداري غير مشروع قد تحصن ضد الإلغاء.

وهذه الحلول وهي:

١. إذا كان باب الإلغاء قد أغلق بفوات الميعاد، فإن باب التعويض يبقى مفتوحاً بمضي مدة تقادم تصل إلى ١٥ سنة طبقاً لقواعد القانون المدني.
٢. إذا كان القرار الإداري لا تحجباً وانقضت مواعيد الدعوى بالإلغاء، فإنه يجوز لكل من يخضع إلى أحكامه أن يدفع بعدم مشروعية القرار اللائحي المطلوب تطبيقه عليه، ولكن القرار التنظيمي يبقى قائماً تجاه الغير.
٣. إذا انقضت مواعيد الطعن إلغاءً بقرار إداري تنظيمي فإنه يجوز للفرد الانتظار حتى صدور قرار فردي طبقاً لأحكام اللائحة فيطعن بالقرار الفردي بالإلغاء.
٤. القاعدة إن القرار الفردي يصبح محصناً بفوات ميعة الطعن، إلا إن هنالك قرارات فردية مستمرة الأثر ومتجددة النتائج، كقرار منع المواطن من السفر خارج البلاد، في مثل هذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق الفرد أن يطلب رفع اسمه من قوائم المنع في كل مناسبة يريد السفر فيها، وكل قرار يصدر برفض طلبه يعد قرارًا إداريًا جديدًا يحق له الطعن فيه بالإلغاء.

٥. حالة تغير الظروف التي صدر في ظلها القرار الإداري، كأن يكون القرار قد صدر استنادًا إلى قضاء معين وعدل لاحقًا عن هذا الحكم، أو إن القرار قد استند إلى تشريع تقرر إلغائه أو تعديله.
٦. حالة ظهور المصلحة بعد انقضاء ميعاد الطعن إذ يكون الميعاد القانوني المحدد لرفع دعوى الإلغاء من تاريخ ظهور المصلحة بالنسبة لصاحب الشأن بعد أن كانت خافية.

المبحث الرابع - إنعدام طريق الطعن الموازي أو المقابل: ص ١٥٤

تخفيفًا عن كاهل مجلس الدولة الفرنسي قرر المجلس عدم قبول دعوى الإلغاء إذا كان الطاعن يستطيع اللجوء إلى طريق قضائي آخر للحصول على ذات النتيجة التي يحصل عليها من دعوى الإلغاء.

أساس نظرية الطعن الموازي:

١. يعتبر البعض أن الطعن بالإلغاء هو طعن احتياطي أو استثنائي لا يجب اللجوء إليه مادام القانون قد نظم دعوى قضائية أخرى يمكن لجوء صاحب الشأن إليها وكان دافع هؤلاء الفقهاء الحد من كثرة الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة.
٢. يرر البعض بأن أساس هذه النظرية لا يقوم على أساس اعتبار الطعن بالإلغاء هو طعن احتياطي، بل إن ذلك يمكن في المبدأ القائل إن الخاص يقيد العام أي منح القواعد الخاصة الأولوية تجاه القواعد العامة، وتطبيقًا لهذا المبدأ فإن مجلس الدولة غير مختص بنظر المنازعات التي جعلها القانون من اختصاص جهات أخرى كالقضاء العادي أو المحاكم الإدارية.

س/ ما هي شروط الطعن الموازي أو المقابل؟ ص ١٥٥

١. يجب أن يكون الطعن الموازي الذي يحول دون قبول دعوى الإلغاء دعوى قضائية، أي ليست مجرد تظلم.
٢. أن يكون الطعن الموازي ممثلًا في دعوى لا مجرد دفع.
٣. يجب أن يؤدي الطعن الموازي على نفس نتيجة دعوى الإلغاء، أي أن يؤدي الطعن الموازي إلى إلغاء القرار المطعون فيه وإزالة آثاره.
٤. أن يكون الطعن الموازي من اختصاص محاكم قضائية أخرى غير مجلس الدولة سواء أكان قضاءً عاديًا أم إداريًا.

الفصل الثاني - أسباب الطعن بالإلغاء: ص ١٥٧

أسباب الطعن بالإلغاء:- هي تلك العيوب التي تصيب أحد الأركان الخمسة للقرار الإداري فتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه. وعيوب الإلغاء، هي:

١. عيب الاختصاص.
٢. عيب الشكل.
٣. عيب مخالفة القانون (عيب المحل).
٤. عيب الانحراف بالسلطة.
٥. عيب السبب.

المبحث الأول - عيب الاختصاص: ص ١٥٨

عيب الاختصاص:- هو عدم القدرة قانونًا على اتخاذ قرار معين وذلك لضرورة صدوره من عضو أو هيئة أخرى.

يمتاز عيب عدم الاختصاص بأنه من النظام العام، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

١. إذا تبين للقاضي صدور القرار الإداري من غير صاحب الاختصاص فعليه التصدي له من تلقاء نفسه، حتى لو لم يثره رافع الدعوى كسبب للإلغاء.
٢. لا يجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص في عقد من العقود المبرمة بينها لأن قواعد الاختصاص ليست مقررة لمصلحة الإدارة بل لتحقيق الصالح العام.
٣. لا يجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بذريعة الاستعجال إلا في حالة الضرورة وتحت رقابة القضاء.
٤. يجوز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل دعوى الإلغاء.
٥. لا يمكن للقاضي التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بالاختصاص.
٦. لا يمكن تصحيح القرار الإداري المعيب بعدم الاختصاص أو إجازته بإجراء لاحق، بل يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة شروط صحيحة.

١. **الدستور**:- يعد الدستور من أهم مصادر تحقيق الاختصاص على مستوى السلطات العامة في الدولة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)
٢. **التشريع العادي**:- يأتي دور المشرع العادي ليعين اختصاصات الهيئات الفرعية لكل سلطة من السلطات عن طريق النصوص القانونية ولكن دون الإخلال بالنصوص الدستورية.

١. صورة عدم الاختصاص الجسم (عيب اغتصاب السلطة).
 ٢. صورة عيب عدم الاختصاص البسيط.
- المطلب الأول - عيب الاختصاص الجسم (اغتصاب السلطة):** ص ١٦٠
- عندما يكون هذا العيب جسيماً لا يعد القرار الإداري باطلاً فحسب بل معدوماً وفاقداً لصفته الإدارية، ولا يخضع للتحصن بفوت ميعاد الطعن. اتفق الفقه والقضاء على حالات محددة لاغتصاب السلطة، هي:

١. صدور القرار من لا يتصف بصفة الموظف العام (فرد عادي).
٢. صدور القرار من موظف لا صلة له بإصدار القرارات.
٣. اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.
٤. اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية.
٥. اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية لا تمت لها بصلة.

أولاً:- صدور القرار من لا يتصف بصفة الموظف العام (فرد عادي):

يتحقق عيب عدم الاختصاص الجسم في هذه الحالة عندما يقوم أحد الأفراد من لا يتمتعون بصفة الموظف العام بإحجام نفسه في مباشرة الاختصاصات الإدارية.

وقد اورد مجلس الدولة الفرنسي استثناءً على ذلك في حالة نظرية الموظف الفعلي وهي حالة صدور قرارات صحيحة ومنتجة لآثارها من لا تتوفر فيهم صفة الموظف العام سواء كانت في الظروف العادية أم الاستثنائية.

١. نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية: وهي حماية للشخص حسن النية الذي تعامل من دون علم بحقيقة الأمر مع من ظهر بمظهر الموظف الفعلي الذي جرى تعيينه بطريقة قانونية ثم اتضح لاحقاً عدم صحة التعيين فتعد القرارات الصادرة من قبل هذا الموظف صحيحة رغم بطلان تعيينه، عدا التصرفات الصادرة بناءً على تفويض غير صحيح فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلانها.
٢. نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية: وهي حالة صدور القرارات الإدارية في الظروف الاستثنائية (كالهرب) من اشخاص عاديين، فلقد عد القضاء الإداري هذه القرارات صحيحة رغم صدورهما من أشخاص ليس لهم علاقه بالوظيفة العامة.

ثانياً:- صدور القرار من موظف لا صلة له بإصدار القرارات: ص ١٦١

وهي حالة صدور القرار الإداري من أحد الموظفين السعاة أو الكتبة، إذ يعد منعدماً ولا وجود له بسبب انعدام صلاحية مثل هؤلاء الموظفين بإصدار القرارات الإدارية.

ثالثاً:- اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية:

إن وظيفة السلطة التشريعية هي سن القوانين وبالتالي يُمنع على السلطة التنفيذية التدخل فيها، وإلا كانت قراراتها في هذا المجال منعدمة وليس لها أي قيمة قانونية.

رابعاً:- اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية: ص ١٦٢

إن اصدار القرارات الداخلة في اختصاص السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية يشكل حالة غضب للسلطة، ويعد القرار بموجبها معدوماً، إلا في الحالات التي يمنح القانون المجالس أو اللجان الإدارية سلطة الفصل في طائفة محددة من المنازعات والتي تعد استثناءً على الأصل.

خامساً:- اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية لا تمت لها بصلة:

تقوم حالة اغتصاب السلطة عندما تعتدي سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا رابطة تبعية بينهما.

المطلب الثاني - عيب الاختصاص البسيط: ص ١٦٣

يقع عيب الاختصاص البسيط داخل السلطة التنفيذية وبين إدارتها وموظفيها وذلك عند مخالفة قواعد توزيع الاختصاص فيتجاوز مصدر القرار حدود اختصاصه.

ولا يؤدي هذا العيب إلى انعدام القرار بل إلى بطلانه وقابليته للإلغاء فحسب، ولا يجوز الطعن فيه بالإلغاء إلا خلال مدة معينة، لأن فوات هذه المدة يعني تحسن هذا القرار

وهناك ثلاث صور لعيب الاختصاص البسيط هي:

١. عيب الاختصاص الموضوعي.
٢. عيب الاختصاص الزمني.
٣. عيب الاختصاص المكاني.

أولاً: عدم الاختصاص من حيث الموضوع:

يعني صدور القرار في موضوع معين يكون من اختصاص موظف أو هيئة غير التي قامت بإصداره. وكما يلي:

١. اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى موازية: وهي حالة قيام جهة إدارية بالتجاوز على اختصاص جهة إدارية أخرى تكون على قدم المساواة معها، كاعتداء أحد الوزراء على اختصاص وزير آخر.
٢. اعتداء سلطة إدارية عليا على اختصاص سلطة أدنى منها: هنالك حالات يكون للمرؤوس فيها حق إصدار القرارات من دون أن يكون للرئيس حق التعقيب عليها، فإذا تصدى الرئيس لها بتبديلها أو إلغائها فإن قرار الرئيس الإداري يعد معيياً بعيب عدم الاختصاص.
٣. اعتداء سلطة إدارية أدنى على سلطة أعلى منها: مثاله أن يصدر قراراً من الوزير بإعفاء الموظف من منصبه كمدير عام، في حين أن الأمر في ذلك يعود إلى مجلس الوزراء.
٤. اعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة لا مركزية: إن السلطة المركزية لها حق الرقابة المسمى بالوصاية الإدارية على السلطة اللامركزية، فهي تصدق على القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لوصايتها أو ترفضه بحالته، وبهذا فإنه لا يجوز لها أن تتجاوز على اختصاصات الهيئات اللامركزية بتعديل قراراتها أو الحلول محلها في إصدارها، وإلا جاءت قراراتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص.

ثانياً: عدم الاختصاص الزمني: ص ١٦٥

- أي يجب على صاحب الاختصاص أن يمارس اختصاصه خلال المدة الزمنية التي يثبت له فيها هذا الاختصاص
- وعليه لا يجوز للموظف أن يصدر قراراً قبل تولية وظيفته أو بعد انتهاء علاقته بالوظيفة العامة وإلا عدت قراراته معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمني.

ثالثاً: عدم الاختصاص المكاني:

- إن القواعد القانونية قد تحدد لرجل الإدارة نطاق إقليمي معين يمارس فيه اختصاصه الممنوح له، ومن ثم لا يجوز لأي موظف تخطي حدود هذا الاختصاص، وبعبارة أخرى يكون عمله معيب بعدم الاختصاص المكاني.
- مثال ذلك لا يجوز لأحد المحافظين أن يمارس اختصاص يخرج عن نطاق محافظته، كإصدار قرار بمنح رخصة عمل لشخص يعمل في محافظة أخرى.

المبحث الثاني - عيب الشكل: ص ١٦٧

عيب الشكل: هو عدم التزام الإدارة بالإجراءات والشروط الشكلية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية.

المطلب الأول - صور قواعد الشكل: ص ١٦٨

استقر القضاء الإداري على التمييز بين الأشكال الجوهرية التي تؤدي مخالفتها إلى بطلان القرار الإداري وإلى الأشكال غير الجوهرية التي لا تؤدي مخالفتها أو عدم اتباعها إلى بطلان القرار الإداري.

أولاً: الأشكال الجوهرية:

يعد الشكل جوهرياً إذا نص القانون على ضرورة اتباعه مقررًا بإبطال ما صدر مخالفاً له.

وتتمثل الإجراءات الجوهرية في مظهرين، هما:

١. الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار الإداري: هي الإجراءات الجوهرية التي نص المشرع عليها وابطل القرار الإداري الذي يصدر مخالفاً لها. كما قد يشترط القانون على الإدارة أخذ رأي جهة إدارية معينة قبل إصدارها للقرار وإن تجاهلت هذا الرأي يعتبر قرارها باطلاً سواء أكان هذا الرأي ملزماً لها أم غير ملزم.
٢. المظهر الخارجي للقرار الإداري: الأصل إن القانون لم يشترط لصدور القرار شكل معين، فقد يصدر على شكل شفاهي أو بالإشارة وقد يشترط في بعض الأحوال ضرورة صدوره مكتوباً وفي هذه الحالة فإن على الإدارة أن تلتزم بنص القانون وتصدره مكتوباً وإلا عد باطلاً، مضافاً إليه التسبب كشرط شكلي جوهرى يترتب على اغفاله بطلان القرار الإداري.

ثانياً: الأشكال غير الجوهرية:

هي الشكليات التي لم يوجب القانون مراعاتها، ولم ينص على جزاء لمخالفتها

- ويعد الشكل غير جوهرى عندما يكون مقررًا لمصلحة الإدارة وحدها، إذ لا يترتب على مخالفته أو اغفاله بطلان القرار الإداري.
- كعدم احترام المواعيد التنظيمية المقررة أصلاً لصالح الإدارة.

المطلب الثاني - وسائل تصحيح عيب الشكل: ص ١٧١

تصحيح عيب الشكل أو الإجراء:- يؤدي هذا التصحيح إلى التقليل من القرارات الإدارية غير المشروعة. كما إنه يغني صاحب الشأن من الطعن في القرار ما دام الإجراء الذي تقوم به الإدارة يؤدي إلى تصحيح العيب الجوهرى.

و يتم تصحيح عيب الشكل الجوهرى عن طريق الاستيفاء اللاحق الذي كان يجب مراعاته قبل إصدار القرار الإداري

آراء الفقهاء بتصحيح الإجراءات المعيبة في القرار الإداري ، هي:

١. ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز تصحيح هذه الإجراءات وحجتم إن إمكانية تصحيح الأوضاع الشكلية بعد إصدار القرار يدفع الإدارة إلى عدم التزوي في اتخاذ قراراتها، ويرون أيضاً عدم جواز تصحيح عيب الشكل عن طريق الاستيفاء اللاحق، إلا في حالات استثنائية كوجود أخطاء مادية لا تؤثر على القرارات (كخلو القرار من التأريخ)
٢. بينما يذهب فريق آخر إلى جواز التصحيح اللاحق وذلك تفادياً لإلغاء القرار لكنهم فرقوا بين الخطأ المادى والقانونى فالماضى يمكن تصحيحه وفي أي وقت بينما الخطأ القانونى يجعله قابلاً للطعن بالإلغاء من ذوي الشأن.
٣. أما في حالة قبول صاحب المصلحة للقرار المعاب بعيب الشكل:

- ف يرى بعضهم أن قبول صاحب المصلحة للقرار ليس من شأنه، لأن الإجراءات الشكلية في القرار لم تقرر لصالح الأفراد وحدهم وإنما من أجل الصالح العام أيضاً، كما إن تنازله عن العيب الشكلي يعني قبوله للقرار وهذا غير جائز، لأن دعوى الإلغاء من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها.

- بينما يرى الفريق الآخر بأن قبول صاحب المصلحة للقرار المعاب بعيب الشكل من شأنه تغطية هذا العيب وتفادي الحكم بإلغاء القرار الإداري. ويمكن أيضاً تغطية عيب الشكل في القرار الإداري إذا نتج عن أسباب معينة اعترف القضاء بها، كعدم سماع دفاع الموظف المخالف لرفضه إبداء أقواله في التحقيق مثلاً.

المبحث الثالث - عيب مخالفة القانون (عيب الحل): ص ١٧٣

يقع عيب مخالفة القانون عندما تخرج الإدارة على أحكام القانون المكتوب كال دستور والتشريع واللوائح، أو غير المكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون، ويعد هذا العيب من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها وقوعاً من الناحية العملية. المادة (٧) فقرة (هـ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩

المطلب الأول - محل القرار الإداري وشروطه: ص ١٧٤

محل القرار الإداري:- هو موضوع القرار المتمثل بالآثار القانونية التي يحملها القرار مباشرة تجاه المراكز القانونية إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً، وسواء أكان فرداً أم تنظيمياً

إلا إن القرار الفردي ينظم المراكز الذاتية والتنظيمي ينظم المراكز القانونية العامة

وحتى يكون القرار الإداري سليماً في محله يجب توافر شرطين أساسيين:

١. أن يكون محل القرار الإداري ممكناً: يعني أن يكون محل القرار ممكناً من الناحية القانونية كأن يصدر قرار بتعيين أحد الأشخاص في درجة وظيفية مشغولة من قبل الغير، فهنا أصبح المحل غير ممكن ومن الناحية الواقعية كأن يصدر قرار بإزالة منزل آيل للسقوط ثم يتضح إن هذا المنزل قد سقط فعلاً قبل صدور القرار.

٢. أن يكون محل القرار مشروعاً: ويصبح المحل غير مشروعاً في حالة تعارض القرار مع القواعد القانونية النافذة، أي إن القرار قد صدر مخالفاً للقانون.

المطلب الثاني - صور عيب مخالفة القانون: ص ١٧٦

يتخذ عيب مخالفة القانون (عيب المحل) ثلاث صور أساسية، وهي:

١. المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: تحصل المخالفة من الإدارة بإتيانها عمل من الأعمال الممنوعة أو المفروضة عليها بموجب القاعدة القانونية.
٢. الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: يحصل هذا الخطأ عند عدم حصول الوقائع المادية أصلاً كصدور قرار تأديبي بفصل أحد الموظفين ثم يتبين عدم اقترافه أي مخالفة تأديبية أو عدم تقدير الإدارة للوقائع كارتكاب الموظف فعل معين ولكنه لا يصل إلى حد فصله من الوظيفة.
٣. الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: قد يكون الخطأ في التفسير عمدياً كأن تتعمد الإدارة مثلاً فضيف إلى النص شرطاً جديداً إلى جانب الشروط المحددة بالقانون لمنح ترخيص في مجال معين وقد يكون غير عمدياً أي أن يكون الخطأ راجعاً إلى غموض أو إبهام في القاعدة القانونية موضوع التفسير.

المبحث الرابع - عيب الغاية (عيب إساءة استخدام السلطة): ص ١٧٨

عيب الغاية:- هو استخدام الإدارة لسلطانها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة سواءً باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أم إنها مغايرة للغاية التي حددها القانون.

مثاله كأن يصدر قراراً بتعيين فلاناً كمدبر لكننا مديرة، ليس لكونه يمتلك عنصر الكفاءة بل لأنه نسيب الوزير الفلاني، أي غاية التعيين ليست للصالح العام.

المطلب الأول - صور عيب إساءة استعمال السلطة: ص ١٨٠

أولاً: الغاية البعيدة عن المصلحة العامة:

إن السلطة العامة ليست امتيازاً شخصياً للموظف العام، بل هي ممنوحة للوظيفة العامة بهدف تحقيق الصالح العام، لذا فإن صدور القرار المخالف للمصلحة يكون معيباً بعيب الغاية وهذه الحالة خطيرة لأن الانحراف هنا مقصود، حيث إن رجل الإدارة يستغل سلطته لتحقيق أغراض لا تتعلق بالمصلحة العامة وحالاتها هي:

١. استخدام السلطة لتحقيق نفع شخصي: يعني أن يُصدر رجل الإدارة قراراً إدارياً بقصد تحقيق نفع شخصي له أو لغيره مثاله كأن يصدر قراراً من الوزير فلان بتعيين أبناء أخته غير الأكفاء تاركاً ذوو الخبرة يتسكعون في الشوارع.
٢. استخدام السلطة بقصد الانتقام: تعد هذه الصورة من أشد حالات استغلال السلطة، فالسلطة تُمارس هنا من أجل إيقاع الأذى بالغير بقصد الانتقام الشخصي والتشفي من دون النظر إلى المصلحة العامة مثاله كأن يصدر قراراً بالاستغناء عن خدمات تدريسي نزيه لامتناعه عن إعطاء الغش لابن سياسي فاشل.
٣. استعمال السلطة لغرض سياسي: حيث يستخدم رجل الإدارة ما يمتلكه من صلاحية لتحقيق أغراض سياسية وليست للصالح العام مثاله كأن تمتنع الإدارة عن قبول تعيين مرشح للوظيفة العامة بسبب انتمائه لحزب آخر.

ثانياً: مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: ص ١٨١

وهي أقل الحالات خطورة، لأن رجل الإدارة يتصرف في حدود الصالح العام فقد يحدد المشرع لرجل الإدارة هدفاً معيناً يسعى لتحقيقه من خلال القرارات الإدارية فإن جاء القرار لتحقيق هدفاً غيره وقع باطلاً لعب انحراف السلطة حتى إذا كانت الغاية هي المصلحة العامة

ومن أمثلة ذلك:

١. ميدان الضبط الإداري: إن هدف سلطة الضبط الإداري تحقيق الأمن العام والصحة والسكينة، فإذا خرجت سلطاتها عن هذه الأغراض كان تصرفها معيَّباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
٢. ميدان الوظيفة العامة: الأصل أن للإدارة سلطة نقل الموظفين مكائياً أو نوعياً لتحقيق مصلحة العمل عن طريق توزيع الموظفين بين الوظائف والأماكن المختلفة، لكن إذا صدر قرار التوزيع بقصد توقيع عقوبة تأديبية بحق أحد الموظفين فإن قرارها يكون معيَّباً في غايته، أي تتخذ من النقل أداة للعقاب.

ثالثاً: إساءة استعمال الإجراءات:

يظهر هذا النوع من الانحراف عندما تستعمل الإدارة إجراء إداري محل إجراء آخر مثاله كحالة لجوء الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقار بدلا من اتباعها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادياً من إطالة الإجراءات.

المطلب الثاني - إثبات عيب إساءة استعمال السلطة: ص ١٨٣

لجأ القضاء الإداري إلى وسائل عديدة لإثبات هذا العيب ومن أهمها:

١. إثبات العيب من أوراق ومستندات الدعوى: يتم الاعتماد بموجب هذه الوسيلة على ملف خدمة الموظف أو أي مستند آخر يمكن أن يسهم في الكشف عن هدف الإدارة والتوصل إلى عيب الانحراف في هذا القرار.
٢. إثبات العيب من خلال إثبات عكس قرينة مشروعية القرار المفترضة: الأصل إن القرارات الإدارية تتمتع بالنسبة لغايتها بقرينة المشروعية، فإذا أثبت صاحب الشأن عكس ذلك فإن قرارها يكون معيَّباً بعيب الانحراف.
٣. إثبات العيب من ظروف إصدار القرار: كأن يصدر القرار في ظروف غير مناسبة أو من دون تأني من قبل الإدارة.
٤. إثبات العيب من خلال نص القرار المطعون فيه: يمكن أن يتم إثبات عيب الانحراف من خلال الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار والتي يجب أن تكون مبررة لاتخاذ وتحقيق الغاية منه والا فيحكم بإلغاء القرار لعيب الانحراف.
٥. إثبات العيب المستمد من قرينة عدم الملائمة الظاهرة في توقيع العقوبات التأديبية: أن عدم الملائمة بين العقوبة التأديبية والذنب المرتكب من الموظف يؤدي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة.

المبحث الخامس - عيب السبب: ص ١٨٥

يعد عيب السبب آخر العيوب التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي في إلغاء القرارات الإدارية

أما في العراق فلم ينص قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ صراحةً على عيب السبب وإنما جرى تفسير النص الوارد في الفقرة (هـ) من المادة السابعة (الخطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تفسيرها) على إنه هو عيب السبب.

السبب:- هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع رجل الإدارة إلى إصدار القرار الإداري

أما عيب السبب:- فهو عدم مشروعية سبب القرار الإداري

مثال الحالة القانونية: كصدور قرار بإحالة الموظف على التقاعد من دون طلب منه

مثال الحالة الواقعية: كأن تتخذ الإدارة قرارات بالحفاظ على الأمن والنظام ثم يتبين عدم حدوث خلل في الأمن العام فإن هذا يعني عدم وجود الحالة الواقعية.

تمييز رقابة القضاء على سبب القرار الإداري في حال كانت الإدارة تتمتع بسلطة مقيدة أو إنها كانت تتمتع بسلطة تقديرية

١. في حالة السلطة المقيدة: يحدد المشرع أسباباً معينة لابد من توافرها قبل اتخاذ القرار الإداري كتحديد شروط الحصول على ترخيص معين.
٢. في حالة السلطة التقديرية: لا يحدد المشرع الأسباب التي يجب أن يستند إليها القرار الإداري، كما هو الشأن بالنسبة لواجب الإدارة في المحافظة على النظام العام عند حدوث خلل به.

يطلب لصحة وسلامة ركن السبب شرطان أساسيان هما: ص ١٨٦

١. أن يكون سبب القرار موجوداً وقائماً حتى تاريخ اتخاذ القرار الإداري: كأن يقدم أحد الموظفين طلباً للاستقالة ثم يصدر قرار بقبول استقالته بعد أن عدل عن طلبه، فهذا القرار معيب بعيب السبب لأن الظروف المكونة لسبب القرار قد تحققت ولكن لم تستمر إلى تاريخ صدور وكذلك الأمر لو تحقق سبب القرار بعد تاريخ اتخاذه بالفعل.
٢. أن يكون السبب مشروعاً: فإذا استندت الإدارة إلى أسباب غير التي حددها المشرع فإن قرارها يكون غير مشروع.

١. **الرقابة على الوجود المادي للوقائع:** يمارس القضاء الإداري رقابته على الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين للقضاء إن الأسباب التي ادعتها الإدارة غير موجودة أصلاً تعين عليها إلغاء القرار لعدم صحة سببه.
٢. **الرقابة على التكيف القانوني للوقائع:** يراقب القضاء الإداري التكيف القانوني للوقائع فإذا تأكد القاضي أن التكيف الذي أجرته جهة الإدارة لهذه الوقائع غير صحيح فإنه يحكم بإلغاء القرار لعيب في سببه.
٣. **الرقابة على ملائمة القرار أو تناسبه مع الوقائع:** تظهر عدم المشروعية في هذه الصورة، عندما تكون درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره.

الفصل الثالث - إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها: ص ١٩٠

تخضع إقامة دعوى الإلغاء إلى إجراءات ومتطلبات يجب مراعاتها والعمل بموجبها إلى حين انتهاء الدعوى ومصادر إجراءات التقاضي الإدارية، هي:

١. **المصدر التشريعي:** حيث تضمن قانون مجلس شورى الدولة أحكاماً خاصة بإجراءات دعوى الإلغاء يضاف إليها القواعد الإجرائية الواردة في قانون المرافعات المدنية إذا وجد نقص في قواعد الإجراءات الإدارية.
٢. **المصدر القضائي:** يتمثل في المبادئ العامة للإجراءات التي يضعها القضاء الإداري لسد النقص في تشريعات إجراءات التقاضي الإدارية ومن أهم هذه المبادئ مبدأ عدم انعقاد المحكمة إلا باكتمال النصاب القانوني من القضاة.

المبحث الأول - الخصائص المميزة لإجراءات القضاء الإداري: ص ١٩١

إن المنازعات الإدارية تختلف في مضمونها وإجراءاتها كثيراً عن المنازعات المدنية فمن أهم الخصائص المميزة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، هي:

أولاً: استقلال الإجراءات القضائية الإدارية عن الإجراءات المدنية:

أي إن القاضي الإداري ليس ملزماً بالرجوع إلى إجراءات القانون الخاص المدنية والتجارية، بل عليه أن يستنبط القاعدة التي يتبعها من واقع الحياة الإدارية بطريقة إنشائية، وله اللجوء إلى قانون المرافعات المدنية على سبيل الاستثناء.

س| ما هي الأسباب التي تميز استقلالية الإجراءات الإدارية عن غيرها؟ ص ١٩٢

١. إن طبيعة العلاقة التي يحكمها القانون الإداري تنظم مصالح عامة بينما القانون الخاص ينظم مصالح فردية.
٢. إن طبيعة دعوى الإلغاء تكون موضوعية عينية هدفها حماية الشرعية وسيادة القانون أما في القضاء العادي تقوم دعوى الإلغاء على خصومات شخصية تستهدف تحقيق مصالح خاصة.
٣. إن الخصوم في دعوى الإلغاء في مراكز متباينة إذ إن الإدارة كطرف في الخصومة الإدارية تتميز عن الطرف الآخر بمالها من امتيازات مهمة، أما الخصوم في الدعوى العادية تكون مراكزهم القانونية متكافئة.

ثانياً: يقوم القضاء الإداري بدور إيجابي في توجيه الإجراءات الإدارية:

إن القاضي الإداري هو الذي يوجه الإجراءات الإدارية على خلاف الإجراءات المدنية التي يهيمن عليها الخصوم فالقاضي هو من يأمر بإيصال عريضة الدعوى للمستدعى ضده ويأمر بتبليغ المذكرات للخصوم ويحدد مهلاً لتقديم المستندات المطلوبة .. إلخ

ثالثاً: إنها إجراءات تتسم بالصفة الكتابية:

أي إن الدعوى الإدارية تمتاز بكونها كتابية، إذ إن المرافعة فيها يلزم أن تتم كتابةً حيث يقدم أطراف الخصومة ادعاءاتهم في مذكرة مكتوبة.

رابعاً: إنها إجراءات تتسم بالبساطة والسرعة:

تتسم الإجراءات الإدارية بالبساطة والمرونة والسرعة في حسم المنازعة الإدارية خلافاً للإجراءات المدنية، وذلك نظراً لهيمنة القاضي الإداري عليها مما يجرها من كل ما يؤخر حسم الدعوى كما إن نفقات الدعوى الإدارية أقل بكثير من نفقات الدعوى المدنية.

المبحث الثاني - إجراءات رفع دعوى الإلغاء: ص ١٩٤

تتضمن إجراءات رفع دعوى الإلغاء ما يلي:

أولاً: تحديد الجهة المدعى عليها:

الأصل إن الفرد في دعوى الإلغاء هو المدعي والإدارة التي اصدرت القرار هي المدعى عليه

إلا إن تطبيق هذه القاعدة يقتضي التفرقة بين حالتين:

- الحالة الأولى: حالة صدور القرار الإداري من جهة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية العامة، حيث ترفع الدعوى في هذه الحالة على ممثل الشخص المعنوي العام فإن وجهت إلى غيره اعتبرت غير مقبولة، ويعد هذا الأمر من النظام العام، والمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها.
- الحالة الثانية: حالة صدور القرار من جهة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن الدعوى ترفع على الوزير الذي تتبعه باعتباره ممثلاً للدولة بالنسبة لوزارته، وخلاف ذلك لا تقبل الدعوى.

ثانياً: تقديم عريضة الدعوى والإجراءات اللاحقة: ص ١٩٥

- ترفع دعوى الإلغاء بأن يقدم صاحب المصلحة طلباً إلى المحكمة المختصة وذلك بعريضة موقعه من قبله أو بتوكيل مُحام عنه.
- تتضمن العريضة البيانات العامة المتعلقة باسم المحكمة وتاريخ تحرير العريضة واسم المدعي ومن يوجه إليه الطلب وصفته ومحل إقامته وموجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه، وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة، والبيانات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه، والتظلم من القرار المطعون فيه إذا كان التظلم وجوبياً بالنسبة للأمر أو القرار وفي مثل هذه الحالة يجب ذكر تاريخ التظلم ونتيجته.

المبحث الثالث - الفصل في دعوى الإلغاء: ص ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩

أولاً: نظر الدعوى:

- يُباشر القاضي الإداري التحقيق بالدعوى في الموعد المحدد للجلسة حيث يبدأ المدعي أولاً بسرد وقائع دعواه كما وردت في ادعائه ويقدم بياناته وشهوده لإثباتها ثم يأتي دور المدعى عليه (الممثل القانوني للدائرة المعنية) في تقديم أوجه دفاعه في حدود لأخته الجوابية ويقدم بياناته عليها.
- ثم تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة ويوقع المحضر القاضي والكتاب والخصوم أو وكلائهم ويحفظ في إضارة الدعوى ويجوز أن يتلى المحضر في المرافعة بناءً على طلب أحد الطرفين.
- وللطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط ألا يغير كل من المدعي والمدعى عليه من موضوع الدعوى، وليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى أية دعوى جديدة باستثناء الدعوى الحادثة.
- وطبقاً لنص المادة ٦١ مرافعات تنظر محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة أمامها في جلسة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سرّاً لمقتضيات المصلحة العامة أو للمحافظة على النظام العام أو مراعاةً للأداب العامة.
- ويترتب على تغيب المدعي عليه أن تتم المرافعة بحقه غيابياً، وإن رأت المحكمة أن الدعوى صالحة للفصل تفصل فيها وإن لم تكن صالحة تؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات.
- أما إذا لم يحضر المدعي أمام المحكمة فللمدعى عليه أن يطلب إبطال عريضة الدعوى وعندئذٍ تثبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقاً للقانون.
- وقد أجاز القانون لمحكمة القضاء الإدارية تأجيل النظر في دعوى الإلغاء شريطة أن يكون سبب التأجيل مشروعاً ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك لحسن سير العدالة كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل ٢٠ يوماً إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ثانياً: التدخل في الدعوى: ص ١٩٨

التدخل في الدعوى:- هو عبارة عن طلب عارض يتقدم به شخص غريب عن الخصومة يمكن أن يتأثر من نتيجة الحكم الذي يصدر فيها.

- نصت المادة ٦٩ مرافعات على الأحكام والضوابط الخاصة بدخول طرف ثالث في دعوى الإلغاء.
- إذ لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى كشخص ثالث منضم لأحد طرفيها، أو طالباً الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا تقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها.
- ويجب أن يكون للمتدخل مصلحة مشروعة تبرر تدخله في الدعوى.

ثالثاً: وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه:

الأصل أن رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري للطعن بقرار إداري معين لا يؤثر على تنفيذه، إلا إنه واستثناءً من هذا الأصل

يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه عند توافر الشروط الآتية:

١. أن يطلب رافع دعوى الإلغاء صراحةً وقف التنفيذ وإلغاء القرار في نفس عريضة الدعوى.
٢. أن يقوم طلب الإلغاء بحسب الظاهر على أسباب جدية، كأن ترى المحكمة من ظاهر الأوراق المقدمة من أطرافها إن طلب الطاعن قائم على أسباب جدية.
٣. توافر حالة الاستعجال، بمعنى إنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار أن تكون نتائج تنفيذه يتعذر تداركها.

المبحث الرابع - الحكم بالإلغاء وتنفيذه: ص ٢٠٠

- بعد أن تصبح الدعوى محيئة للحكم تصدر المحكمة حكمها بالاتفاق أو بأكثرية الآراء، فإذا تشعبت الآراء وجب على العضو الأقل درجة أن ينضم إلى أحد الآراء لتكوين الأكثرية.
- ويتم إصدار الحكم في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها المحكمة لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا من تاريخ تفهيم ختام المرافعة.
- أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في النطق بالحكم حيث يتم ذلك علانية فإذا صدر هذا الحكم وجب على جهة الإدارة احترامه.

أولاً: حجية الحكم الصادر بالإلغاء:

الأصل أن حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف النزاع وفي هذه الحالة تسمى بالحجية النسبية أما إذا امتد أثرها إلى الغير تسمى بالحجية المطلقة. أما بالنسبة إلى دعوى الإلغاء فإن حجيته مطلقة على كافة الأفراد وجمعات الإدارة وجمعات القضاء الأخرى، إذ إن الحكم الصادر بالإلغاء يحوز على الحجية المطلقة سواء أكان هذا الإلغاء كلياً أم جزئياً.

ثانياً: تنفيذ حكم الإلغاء: ص ٢٠٢

بعد صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري يجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذه تنفيذاً كاملاً دون تحايل أو عرقلة أو تباطؤ أو تراخي في التنفيذ. وإن التزم الإدارة بالتنفيذ ينطوي على التزامين إيجابيين وسلبيين:

١. الالتزام الإيجابي: يتمثل في اتخاذ الإدارة ما يلزم من إجراءات لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى، وإزالة آثاره القانونية والمادية.
٢. الالتزام السلبي: يتمثل من جانب الإدارة في عدم قيامها بتنفيذ القرار الملغى من جهة وبامتناعها عن إصداره من جديد بنفس منطوقه ومضمونه.

ثالثاً: جزاء امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء: ص ٢٠٤

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري يؤدي إلى إمكانية رفع دعوى إلغاء جديدة ضد قرار الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء، كما تتقرر مسؤولية الإدارة والموظف جنائياً ومدنياً عن عدم التنفيذ.

١. الجزاء المدني (التعويض): إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء يعد عملاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الإدارة والموظف المسؤول عن عدم التنفيذ متضامنين في دفع التعويض للمحكوم لصالحه.
٢. الجزاء الجنائي: حسب نص المادة ٣٢٩ عقوبات يترتب على امتناع الموظف المسؤول عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء تعرضه لجزاء جنائي يتمثل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإضافة للجزاء الجنائي يفرض عليه جزاء مدني يتمثل في التعويض، لأن مسؤوليته شخصية.

الباب الخامس - قضاء التعويض (القضاء الكامل): ص ٢٠٧

دعوى التعويض:- هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر جراء تصرف أو عمل الإدارة. وتعد دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل، فقضاء الإلغاء على الرغم من أهميته إلا إنه لا يضمن للأفراد تغطية ما يترتب على القرارات المعيبة من أضرار طيلة مدة نفاذها، لأن رفع دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

س| ما هي أهمية وجود دعوى التعويض إلى جانب دعوى الإلغاء؟

١. إن قضاء التعويض يكمل الحماية التي يسبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد من خلال تعويضهم عن الأضرار.
٢. قد يغلق باب الطعن بالإلغاء ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحاً.
٣. لا تكون دعوى الإلغاء مجدية إذا نفذ القرار الإداري فوراً واستحال تدارك آثار تنفيذه، كصدور قرار بهدم جدار منزل، إذ لا يبقى أمام من صدر القرار ضده سوى المطالبة بالتعويض.

٤. يراقب القضاء الإداري مشروعية قرارات الإدارة، أما أعمالها المادية فيراقبها القضاء الإداري أو العادي عن طريق دعوى التعويض.

الفصل الأول ص ٢٠٩

عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائية:

المبحث الأول - عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية: ص ٢١٠

الأعمال التشريعية:- هي كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين أو قرارات

- الأصل إن للمشرع الكلمة العليا في تنظيم المجتمع بواسطة التشريعات من دون التأثير بما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار لبعض الأفراد في المجتمع
- إذ إن الدولة غير مسؤولة عن القوانين التي يضعها المشرع لتنظيم المجتمع ويجب على الفرد احترامها وتحمل ما ينجم عنها من اعباء، لأن الهدف من وضع هذه القوانين هو تحقيق الصالح العام.

ويستند مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية على عدد من الحجج

هي:

١. فكرة سيادة الدولة وحريتها في إصدار ما تشاء من التشريعات حيث يعد القانون تعبيراً عن سلطة الدولة صاحبة السيادة التي يجب أن لا تخضع لأحد ولا تكون مسؤولة أمام أحد.
٢. إن الضرر الذي تسببه القوانين لا يتصف بالخصوصية، إذ إن القانون يضع قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع فلا يتصور حدوث ضرر خاص بسببه، فإن حدث الضرر سيكون عامًا ومن ثم لا مجال للتعويض عنه.
٣. إن التعويض إنما يكون على أساس الخطأ والخطأ لا يمكن أن ينسب إلى المشرع، لأن المشرع وحدة يقرر معايير الخطأ والصواب.
٤. إن تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها يؤدي إلى عرقلة الإصلاح لأن الدولة ستتردد كثيراً وتحجم عن القيام بتطوير قوانينها إن كانت تعلم سلفاً بأن ذلك سيعرضها للمسؤولية ويلزمها بدفع تعويضات لمن أصابهم ضرراً من قوانينها الإصلاحية.

س| ما هي الشروط التي أوجب مجلس الدولة الفرنسي توافرها للحكم بالتعويض؟ ص ٢١٢

١. سكوت المشرع عن فكرة التعويض بحيث لا يؤديها أو ينفها.
٢. أن تكون المصالح التي لحقتها الضرر مشروعة، أي غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
٣. يجب أن يكون الضرر الناتج عن القانون خاصاً مباشراً وجسماً.

المبحث الثاني - عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية: ص ٢١٤

الأصل العام عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية والمراد بالأعمال القضائية هي التي تصدر عن القضاء سواء كان قضاءً عادياً أم استثنائياً.

س| ما هي مبررات عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية؟

١. استقلال القضاء: لكي يتمكن القضاء من القيام بأداء مهامه تقرر مبدأ استقلاله وعدم خضوعه لأي سلطة، لذا فإن الحكومة غير مسؤولة عن أعمال القضاء حيث إن القضاء مستقلين لا سلطان عليهم غير القانون.
٢. عرقلة سير العدالة: إن تقرير المسؤولية عن أعمال القضاء يؤدي إلى تردد القضاء في إصدار الأحكام، كما إن دفع التعويض من الخزنة العامة يتقل كاهل الدولة.
٣. حماية الأحكام: يتطلب الصالح العام وضع حد للمنازعات وذلك باعتبار الحكم الصادر في النزاع عنوان الحقيقة فيما قضى به.
٤. حداثة قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية: إن أساس هذه القاعدة تاريخي، إذ كانت القاعدة في الماضي هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها بصفة عامة، نظراً للمزج بين شخصية الملك الذي لا يسأل عن الخطأ وبين شخصية الدولة التي كان الملك يعمل باسمها.

س| ما الاستثناءات على قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية؟ ص ٢١٥

١. مسؤولية الدولة في حالة براءة المحكوم عليه بحكم نهائي: إذ إن الدولة ملزمة بتعويض من يتقرر براءته من الحكم الصادر ضده.
٢. مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة رجال القضاء: حيث أجازت المادة ٢٨٦ مرافعات لكل من طرفي الخصومة أن يشكو القاضي أو هيئة المحكمة أو أحد قضاتها في الحالات الآتية:

- إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون.

- إذا قبل المشكو منه منفعة لمحاباة أحد الخصوم.

- إذا امتنع القاضي عن احقاق الحق.

الفصل الثاني - مسؤولية البولة التقصيرية عن أعمالها الإدارية: ص ٢١٧

إذا ألحقت تصرفات الإدارة ضرراً لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التزمت بالتعويض

- حيث نصت المادة ٢١٩ مدني على أن (الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، إذا كان الضرر ناشئاً عن تعدي وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم)
- ولم يقتصر القضاء الإداري على إقامة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ فقط وإنما أقامها أحياناً من دون خطأ على أساس فكرة المخاطرة وتحمل التبعة.

المبحث الأول - مسؤولية الإدارة الناجمة عن الخطأ: ص ٢١٩

- إن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة عن أخطائها التي تلحق ضرراً بالأفراد هو مبدأ مساواة المواطنين في تحمل الأعباء العامة.
- فإذا ترتب على خطأ الإدارة ضرراً خاصاً ببعض الأفراد وجب تعويضهم حتى لا يتحملوا وحدهم عبء هذا الضرر.

تتحقق مسؤولية الإدارة في هذا النطاق بتوافر ثلاثة أركان، هي:

١. الخطأ الذي ارتكبه الإدارة.
٢. الضرر الذي أصاب الفرد.
٣. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

المطلب الأول - ركن الخطأ: ص ٢٢٠

الخطأ: هو مخالفة أحكام القانون الممثلة في تصرف قانوني أو عمل مادي ويأخذ صورة عمل إيجابي وهو القيام بعمل يجرمه القانون أو سلمي ينشأ في صورة الامتناع عن عمل يوجبه القانون.

إن الإدارة لا تخطئ إلا بواسطة العاملين لديها والخطأ الذي يقع منهم في الإدارة أما أن يكون شخصياً يسأل عنه مرتكبه وأما أن يكون مرفقياً تسأل عنه الإدارة.

أولاً: الخطأ الشخصي:

الخطأ الشخصي: هو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتقع مسؤوليته على عاتقه شخصياً، ويدفع التعويض من ماله الخاص وتكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر هذا النوع من الخطأ.

الخطأ المرفقي: هو الذي ينسب فيه الخطأ أو التقصير إلى المرفق ذاته وتتحمل الإدارة مسؤوليته لوحدها فتدفع التعويض من أموالها وتختص المحاكم الإدارية بنظره.

من أهم المعايير التي ميزت بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، هي:

١. معيار النزوات الشخصية: بموجبه يعد الخطأ شخصياً إذا كان الفعل الذي ارتكبه الموظف مطبوع بطابع شخصي يكشف عن سوء النية لدى الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته بقصد تحقيق منافع شخصية، ويعد الخطأ مرفقياً إذا كان الفعل الضار الذي ارتكبه الموظف غير مطبوع بطابع شخصي ينبئ عن أن الموظف عرضة للخطأ والصواب.
٢. معيار جسامة الخطأ: يعد الخطأ شخصياً إذا بلغ من الجسامة حداً لا يمكن اعتباره من الأخطاء العادية التي يتعرض لها الموظف عند قيامه بواجبات وظيفته ويكون الخطأ جسيماً عندما يتجاوز حدود اختصاصاته القانونية أو عندما يرتكب جريمة جنائية.
٣. معيار الانفصال عن الوظيفة: يعد الخطأ شخصياً إذا قام الموظف بعمل لا علاقة له مادياً بواجبات الوظيفة، بينما يعد الخطأ مرفقياً إذا كان العمل الخاطئ داخل ضمن أعمال الوظيفة ولا يمكن فصله عنها.
٤. معيار الغاية: إذا تصرف الموظف بحسن نية لتحقيق الأهداف المنوطة بالإدارة فإن خطأ الموظف في هذا التصرف يعد خطأ مرفقياً حتى لو كان الخطأ جسيماً بينما يعد الخطأ شخصياً حتى لو كان يسيراً طالما أن الموظف قد قصد من عمله تحقيق أغراض خاصة.

س| ما هي الحالات التي تسأل فيها الإدارة عن خطأ الموظف الشخصي؟ ص ٢٢٤

١. الخطأ الشخصي المصحوب بخطأ مرفقي: في هذا السياق يمكن مسألة الإدارة لوحدها عن الخطأين على أن لها الرجوع على الموظف بما يناسب حجم الخطأ الصادر منه، ويتولى القضاء الإداري تحديد نصيب كل من الإدارة والموظف في التعويض.
٢. الخطأ الشخصي المرتكب أثناء الخدمة: توصل القضاء الفرنسي في مرحلة لاحقة من التطور إلى تقرير مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي غير المصحوب بخطأ مرفقي، وذلك إذا وقع الخطأ من الموظف المسؤول أثناء الخدمة.
٣. الخطأ الشخصي المرتكب بأدوات المرفق: قرر القضاء الفرنسي مسألة الإدارة عن أخطاء الموظفين الواقعة خارج الخدمة ولكن بأدوات المرفق وهذا ما يحصل في حوادث السيارات التي يخرج بها السائقون في مهمات رسمية ولكنهم يستخدمون هذه السيارات الحكومية لأغراض شخصية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء.

ثانياً: الخطأ المرفقي: ص ٢٢٥

الخطأ المرفقي:- هو الخطأ الذي ينسب للمرفق ذاته حتى ولو كان الذي قام به مادياً أحد الموظفين. وتمثل ذلك الخطأ في عدم أداء المرفق للعمل المكلف بأدائه فيتربط على موقفه السليبي ضرراً يصيب الأفراد، فهنا تسأل الإدارة عن تعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ.

س| ما هي صور الخطأ المرفقي؟ ص ٢٢٦

١. سوء أداء المرفق للخدمة: تطبيقاً لفكرة الخطأ المرفقي فالدولة تلتزم بالتعويض إذا أدى المرفق الخدمة على وجه سيء.
٢. عدم أداء المرفق للخدمة: يحكم مجلس الدولة بمسؤولية الدولة بالتعويض في حالة امتناع الإدارة عن القيام بأمر كان من الواجب عليها القيام به.
٣. بطئ المرفق في أداء الخدمة: قرر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة بالتعويض لبطء الإدارة أو تأخرها في أداء الخدمة من دون مبرر.

س| كيف يتم تقدير الخطأ المرفقي؟ ص ٢٢٨

لا يحكم على الدولة بالتعويض لمجرد ارتكابها عملاً خاطئاً بل يتطلب الأمر توافر درجة معينة من الجسامة في الخطأ المنسوب للدولة، والقضاء هو الذي يقرر جسامة الخطأ

وذلك في ضوء عدد من العناصر، هي:

١. وقت وقوع الخطأ: ميز مجلس الدولة الفرنسي بين الخطأ المرفقي الذي يقع في الظروف العادية والذي يقع في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب فإن ما يعد خطأ في الظروف العادية قد لا يعد كذلك في الظروف الاستثنائية.
٢. مكان وقوع الخطأ: فرق مجلس الدولة الفرنسي بين مكانين فإذا كان المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته في العاصمة مثلاً عد الخطأ بسيطاً لتقرير المسؤولية وتشدد إذا كان المرفق يؤدي خدماته في مناطق نائية.
٣. ظرف المرفق: إذا كانت الخدمة التي يؤديها المرفق سهلة يقيم المجلس مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ البسيط ويطبقها على أساس الخطأ بالغ الجسامة إذا كانت الخدمة صعبة.
٤. طبيعة المرفق وأهميته: يشدد مجلس الدولة مسؤولية المرافق الصحية وذلك لأهميتها، بينما في الجهاز الإداري قد يكتفي بالخطأ البسيط لتقرير المسؤولية.
٥. موقف المضرور لإزاء المرفق: يفرق المجلس عند تقديره للخطأ ما بين إذا كان المضرور مستفيداً من المرفق أم إنه غير مستفيد منه فيتطلب درجة أكبر من الخطأ في الحالة الأولى بينما يتساهل في تقدير درجة الخطأ في الحالة الثانية.

المطلب الثاني - ركن الضرر: ص ٢٣١

لا يترتب خطأ الإدارة حقاً في التعويض لأحد ما لم ينشئ عن هذا الخطأ ضرر تتوافر في شروط معينة.
ونبين فيما يأتي شروط الضرر وأنواعه:

أولاً: شروط الضرر:

يشترط في الضرر الذي يؤدي إلى مسؤولية الإدارة شروط عديدة، هي:

١. يجب أن يكون الضرر مباشراً.
٢. يجب أن يكون الضرر محققاً.
٣. يجب أن يكون الضرر خاصاً.
٤. يجب أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني.
٥. يجب أن يكون الضرر قابلاً للتقدير بالتقود.

ثانياً: أنواع الضرر:

١. الضرر المادي: وكل ضرر يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية.
 ٢. الضرر الأدبي أو المعنوي: هو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية.
- قد أقر المشرع العراقي بأن الحكم بالتعويض يشمل الضرر المادي والأدبي أيضاً وذلك بنص المادة ٢٠٥ مدني.

المطلب الثالث - العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: ص ٢٣٤

هي الركن الثالث من أركان المسؤولية، إذ يجب أن توجد رابطة سببية بين خطأ الإدارة والضرر الذي أصاب المضرور فإذا انعدمت العلاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر بسبب اجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور تنتفي مسؤولية الإدارة.

- إن السبب الأجنبي لا يعني الإدارة كلياً من المسؤولية إذا كانت الإدارة قد ساهمت بشكل أو بآخر في أحداث الضرر.
- أما إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ الغير أو خطأ المضرور هو وحده المتسبب في وقوع الضرر فإن الإدارة تعفى من المسؤولية.

المبحث الثاني - مسؤولية الإدارة القائمة من دون خطأ: ص ٢٣٥

تسمى هذه النظرية بالمسؤولية على أساس المخاطر أو تحمل التبعة مفادها إن نشاط الإدارة ما دام في صالح الجماعة فلا يجوز أن يتحمل ضرره من وقع عليه وحده وإنما يتحمله الجميع تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، علماً أن القضاء العراقي قد اعتمد هذا المبدأ في بعض احكامه.

المطلب الأول - المسؤولية القائمة من دون خطأ في فرنسا: ص ٢٣٦

أقر مجلس الدولة الفرنسي بأنه إذا تسببت الدولة بأعمالها في إلحاق ضرر ببعض الأفراد فإن لهم مسألتها بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية بتوافر ركنين هما الضرر والعلاقة السببية وذلك انطلاقاً من متطلبات العدالة.

الحالات التي تقوم فيها مسؤولية الإدارة بغير خطأ:

١. مسؤولية الإدارة عن الفعل المشروع لوظيفتها.
٢. مسؤولية الإدارة اصابات العمل.
٣. مسؤولية الإدارة عن أضرار الاشغال العامة.
٤. مسؤولية الإدارة عن نشاطها الخطر.

المطلب الثاني - المسؤولية القائمة من دون خطأ في مصر: ص ٢٣٨

- إن القضاء المصري العادي يرفض الأخذ بمسؤولية الإدارة من دون خطأ حيث إنه لا يقرر مسؤوليتها إلا على أساس الخطأ الثابت وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني.
- كما إن القضاء الإداري لا يأخذ بمبدأ مسؤولية الإدارة من دون خطأ، بل إنه لا يقيم مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، إلا في الحالة التي يقرر فيها المشرع بتشريعات خاصة اعتبار الخطأ أساس مسؤوليتها في التعويض.

المطلب الثالث - المسؤولية القائمة من دون خطأ في العراق: ص ٢٤٠ - ٢٤٢

نظم المشرع العراقي مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها بنص خاص ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية، وتحت عنوان المسؤولية عن فعل الغير هذا وإن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مقترض من جانب الإدارة مفاده إنها لم تقم بما ينبغي من الرقابة والتوجيه وبذل الحيلة لمنع الموظف من ارتكاب الخطأ.

محرم الدين
الشيخ

تمت بحمد الله وفضله



تم نشر الملف في قناة شبكة قانونيون على التلكرام
تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الكتب
القانونية الدراسية والعامة بالإضافة الى الملازم ،
الملخصات ، نماذج دعاوى مختلفة ، المتون
القانونية ، وغيرها من الأمور .

رابط القناة اذا كنت ترغب في الانضمام معنا ↓

https://t.me/iraq_law5
